

《民事訴訟法教程》

第二卷

宣告之訴中之普通訴訟程序

（法律課程三年級教材）

葡文原著：Cândida da Silva Antunes Pires

中文翻譯：馮文莊

（一九九八年十一月中文初稿）

二〇〇一年 郭健雄修訂

二零零二／二零零三年度 郭健雄，邱庭彪修訂

目錄

第一章 通常訴訟程序

第一節 概述

1. 訴訟關係之成立
2. 宣告之訴中之普通訴訟程序：進行之各個階段

第二節

訴辯書狀階段（fase dos articulados）

3. 訴辯書狀的概念（Noção de articulados）
4. 起訴狀（petição inicial）
5. 請求之類型（modalidade do pedido）
6. 提起訴訟
7. 分發（distribuição）
8. 預付金（perparo inicial）
9. 初端批示（despacho liminar）
10. 駁回批示（despacho de indeferimento）
11. 補正批示（despacho de aperfeiçoamento）
12. 傳喚批示（despacho de citação）
13. 傳喚被告人
14. 傳喚之效果（efeitos da citação）
15. 被傳喚人可持之立場
16. 不到庭（revelia）
17. 答辯（contestação）
18. 間接防禦：抗辯事由
19. 直接防禦：提出爭執（impugnação）
20. 反訴（reconvenção）
21. 提交答辯及續後行為
22. 原告之反駁
23. 再答辯（tréplica）
24. 嗣後訴辯書狀（或稱為：嗣後訴辯書狀）
25. 宣告之訴之訴訟關係之變更

第三節

清理及準備階段（fase do saneamento e preparação do processo）

26. 概述
27. 清理階段之實體內容

- 28. 清理階段之形式內容
- 29. 試行調解
- 30. 清理批示 (despacho saneador)
- 31. 事實事宜之篩選
- 32. 待證事實列之製作 (elaboração do questionário)
- 33. 聲明異議 (reclamações)
- 34. 通知當事人進行舉證

第四節

調查階段 (fase de instrução)

I 證據與舉證責任 (prova e ónus de prova)

- 35. 證據之概念
- 36. 主張責任 (ónus da alegação) 與舉證責任 (ónus da prova)
- 37. 舉證責任之負擔
- 38. 反證責任 (ónus da contra-prova)
- 39. 消極事實之證明 (prova do facto negativo)
- 40. 舉證責任之約定倒置

II

證據方法 (meios de prova)

第一分節

書證 (prova por documentos)

- 42. 文書之概念及其種類
- 43. 公文書之類別，其證明力及可有之瑕疵
- 44. 私文書之類型
- 45. 書證之提出
- 46. 文書之歸屬 (destino dos documentos)
- 47. 考慮文書之條件 (condições de atendibilidade dos documentos)
- 48. 對文書提出爭執 (impugnação de documentos)

第二分節

當事人陳述之證據 (prova por confissão das partes)

- 49. 自認之概念
- 50. 自認之方式
- 51. 當事人陳述 (depoimento de parte)
- 52. 如何及在何處作陳述

第三分節

鑑定證據（prova pericial）

53. 概念

第四分節

勘驗（prova por inspecção judicial）

54. 勘驗之概念

第五分節

人證（prova testemunhal）

55. 概念

第五節

辯論階段（fase de discussão）

56. 辯論之概念

57. 口頭方式。其批評性評論

58. 辯論及審判聽證前之預備（preliminares da audiência de discussão e julgamento）

59. 在誰人面前進行辯論

60. 聽證之手續（formalidades da audiência）

61. 事實審（julgamento de facto）

62. 對案件法律事宜之辯論

第四節

判決階段（fase da sentença）

63. 判決之概念

64. 不正當利用訴訟

65. 判決內容之限制（limites da condenação）

66. 判決之效果（efeitos da sentença）

67. 判決之公開性

68. 判決之瑕疵與補救

69. 簡易訴訟程序

第一章 通常訴訟程序

第一節 概述

1. 訴訟關係之成立

起訴 (demanda)

1.1. 前言

先前我們學習起訴前出現之問題：誰人可起訴，如何被代理，應向那個法院起訴，應採用之訴訟形式……等；之後我們分析了關於一般原則及訴訟前提之內容。

至此所作之分析乃相當於訴訟程序靜態之一方面。所提出及解決之問題同訴訟現實生活無關——指動態之生活，一如“動態”這個術語所指般。

正是這方面有待指出，現在我們在行為之時間連貫性上考慮程序，學習其步驟，或慣稱之程序之進程 (marcha do processo)。

1.2. 訴訟法律關係之構成行為：起訴 (demanda)

如何提起一訴訟程序？如何建立訴訟法律關係 (relação jurídica processual)？

無論欲從一司法機關中獲得一宣告 (declaração)、或欲執行一司法執行名義 (um título executivo judicial)，或對權利之實行採取保護措施 (提起一宣告、執行或保全措施)，訴訟程序必始於起訴 (demanda)。

起訴乃指原告人要求法院介入之行為、以獲得對其所主張權利之保護。

1.3. 訴之要素 (elementos da demanda)

邏輯上我們可將起訴這個行為分成兩部份：

- a) ——主張國家之法律保護；
- b) ——案之個別化。

現在看看其理由所在及這些訴之要素範圍：

(1)如上所述，在民事訴訟程序內實程序推動原則 (princípio do impulso processual 第3條第1款)，即訴訟法律關係不會在無當事人作出主動之情況下成立：無原告人則無訴之存在 (nemo iudex sine actore)。此原則載於《民事訴訟法典》第5條 (處分原則)，其中規定：“程序之啟動及推動由當事人負責”。如沒有要求解決衝突之人請求得到國家以法律保護作出表示，法院是不會主動對衝突作出表示。

故需有第一個要件 (相當於兩個要素之中一個)，在理論觀點上，在任何起訴 (demanda) 內我們皆可如此區分：請求國家給予法律保護，此為啟動司法機關活動之必要條件 (condição sine qua non)。

(2)除了 (訴訟) 程序推動原則外，還有另一個值得學習之原則。我們是指

法官不越求原則（*ne eat iudex ultra petitem*），即法官不得超越由原告人提出之請求，雖然法律容許原告人可有效地提出更多之請求¹。此外，由當事人主張之事實是法院唯一可考慮之事實（《民事訴訟法典》第 5 條第 2 及 3 款、第 564 條第 1 款及第 571 條第 1 款 e 項）。

基此，除了向國家主張給予法律保護外，在起訴狀內原告人應作出個具體化意思表示、即載明其請求之標的（*objecto da pretensão*），指出其所依據之事實。這是起訴（*demanda*）之第二個要素：爭議標的之具體化。

1.4. 撮要（*resume*）

綜合言之：

(1) 訴訟程序始於起訴（起訴狀）：

(2) 程序包含兩個基本要素（必須之要素）：向國家主張給予法律保護及利益衝突之標的之具體化——透過原告人之請求向法院提出。

1.5. 起訴（*demanda*）之效果。訴訟法律關係

起訴（*demanda*）引致訴訟法律關係之建立。

訴訟法律關係這個概念成為廣泛爭議之標的。有人否認這個概念，對訴訟之基礎建議使用其他概念，例法律狀況（*situação jurídica*）之概念（Gold Schmid 學者就如此主張）或法律制度（*instituição jurídica*）（Guasp）²。

我們不深入探討這個課題，我們採用接受訴訟法律關係概念之主流學理，但對其性質及主體則產生爭議。

我們僅綜合指出各種不同之學理意見：

(1) 對部份學者來說，訴訟法律關係很簡單，只由一個聯繫（*um vínculo jurídico*）形成：原告人之請求是向被告提出，而被告之反對則向原告提出。

(2) 對其他學者來說，訴訟法律關係是一種複合關係，由兩種或幾個局部關係組成：第一種關係是原告人與法院間之關係³；第二種關係是法院與被告人。

原告人之請求（*pretensão*）並非向被告提出，而是向法院提出。由法院審定原告人之請求。倘請求屬於可行之請求，法院則命令傳喚（*citar*）被告人。

倘被告人參加訴訟，並非向原告提出反對（*oposição*），而是向法院提出；必由法院審定其理由是否成立。

故訴訟法律關係是一種複合法律關係（*relação jurídica complexa*）——指由原告人與法院、以及被告人與法院間訂立之關係。故可將這個理論稱為角形論（*teoria angular*）。

¹ 在勞動訴訟方面則不同，因為容許判處多於請求之數額。關於這點，見由 Palma Carlos 著之《勞動訴訟之當事人》第 18 頁及續後。

² 見《民事程序評釋 I》意大利文作品，第 19 頁。

³ 很明顯，當中談及原告人與法院間之關係，但正確言之，應指原告人與國家間之關係，但正確言之，應指原告人與國家間之關係，因為法院乃國家之機關。

(3)最後，部分學者發揮得更深入，認為：除了這種關係外（原告人——法院，被告人——法院），還有被告人與原告人間之第三種關係，自被告人參加時起建立。

慣稱此學理為三角論（teoria triangular）⁴。

在上述多個理論中，第二個理論值得我們讚同。

為此，倘指原告人與被告人互雙對立，則只限於在實體法方面。在程序上，兩人向國家提出，而國家則由法院代表。如此，（例如）被告人無權直接要求閱覽原告人附隨入卷宗之文件，雖然這些文件對其辯護有作用，但有權要求法院通知原告人交出有關文件（《民事訴訟法典》第 455 條第 1 款）。

訴訟法律關係是一種角形關係，由兩種連繫組成，一是國家與原告人之間，另一則是國家與被告人之間。

留意：起訴（demanda）只建立前者之聯繫（vínculo）；後者是由傳喚被告人時方建立。

訟爭關係（instância）（法律用此術語正是指訴訟法律關係）自起訴（demanda）起存在，即原告人向法院提起訴訟之時（第 211 條），但只有其中一個元素：原告人與法院間之關係。倘認為請求屬於可行，則命令傳喚被告人，自傳喚行為起訴訟關係方完整。

1.6. 接續，僅學習宣告之訴之普通訴訟程序中之通常程序（processo na forma ordinária）

通常程序是以起訴（demanda）使程序開始運行，而程序是透過各個連貫之行為而開展，現在我們看看這種連貫性。

我們僅學習宣告之訴之普通訴訟程序中之通常（形式之）程序。

學習這個通常（訴訟）程序之理由有兩個：

(1)宣告之訴（acção declarativa）先於執行之訴（acção executiva），自然地我們先學習前者，

(2)此為所有訴訟程序之典範形式（forma modelo），唯一有詳盡規範之程序，所有其他程序皆以此程序為補充形式——此為普通訴訟程序中之通常（訴訟）程序。

2. 宣告之訴中之普通訴訟程序：進行之各個階段

一個程序是一連串動性之行為，有一個預定之方式、並以實現某特定目的。在程序過程裏可區分不同之階段，為了一個主要目的而作出一套行為。先有方式（termos）之問題，之後出現另一個問題：提出證據；之後有另一個階段：辯論原因（causa）……等。這一套行為，各有其本身之意思及擔當一種特定功能，稱為訴訟程序之階段（fases do processo）。

⁴ 見由 José Albertos dos Reis 著之《民事訴訟法典評釋》，第三卷，第 21 頁及續後。

宣告之訴中之普通訴訟程序，在理論上分成下述幾個階段：

- (1) 訴辯書狀階段 (fase dos articulados)；
- (2) 清理及準備階段 (fase do saneamento e preparação do processo)；
- (3) 調查階段 (fase da instrução)；
- (4) 辯論及審判階段 (fase da discussão e julgamento)；
- (5) 判決階段 (fase da sentença)。

但要忠告一點，其實在上文已默示地指出了：

雖然所述將各階段個別化之標準 (critério da individualização das fases) 是組成每個階段之行為之普通目的為準，所列之五個階段是宣告之訴中之普通程序之時間順序。換言之，倘按照邏輯標準，可將本應屬於另一個階段之行為列入某階段內。

我們用例子說明這點。

2.1. 訴辯書狀階段

在本階段內決定了案件進行之方式 (termos da causa)。雙方當事人提出其關於事實之版本 (versão dos factos) 及引致其要求對訴裁定為理由成立之法律理由 (Razões de Direito) (原告人之請求)；或理由不成立或有不當情事 (被告人之反對) (oposição do réu)⁵。

當事人提出之事實版本及法律依據載於訴訟文書內，《民事訴訟法典》第 101 條) 稱此為訴辯書狀。

在這種通常訴訟形式內，訴辯書狀 (articulados) 通常有兩份：

起訴狀 (petição inicial)——原告人提出其請求之書狀，指出其請求之依據；

答辯狀 (contestação)——被告人直接或間接地反對原告人請求之書狀。

在法律所定之情況下，還可以有另外兩份訴辯書狀：

原告之反駁 (réplica)——原告人堅持其請求之書狀；

被告之再答辯 (Tréplica)——被告人堅持其防禦 (辯護) 之書狀。

除了這些書狀外，還可以有其他書狀。

倘出現第 218 條所述之任一種情況，被告人可在答辯狀內提出一個或多個針對原告人之請求。這就是反訴 (reconvenção)。

反訴請求 (pedido reconvenional) 必須在答辯狀內提出 (第 419 條)。對於這個請求，被告人變成原告人——反訴人 (reconvinte)，而原告人則變成被告人——被反訴人 (reconvindo)。

提出反訴後，被反訴之原告人可在原告之反駁 (réplica 第 420 條，b 項) 內就反訴提出防禦 (辯護) (defesa)。倘有原告之反駁及原告人提出一項抗辯事由

⁵ 稍後我們會知道，被告人之反對可以是指訴理由不成立，引致駁回請求，或主張欠缺訴訟前提——倘證明則引致駁回起訴。

(excepção)，被告人可作出被告再答辯 (tréplica) (第 421 條)。

另一方面，在第 425 條所述之情況下，還可有嗣後訴辯書狀 (articulados supervenientes)。

提交訴辯書狀階段在程序進行方面十分重要，因為通則是法院不得審理當事人無在訴辯書狀中陳述之事實 (factos articulados) (第 564 條)。書狀階段之目的正是設定案進行之方式 (termos da causa) 及向法官提出訴訟案件。

然而，在上文我們已指出，程序之各個階段並非互不涉及之分隔階段。為此，在書狀階段內，可作出某些證據行為 (通常亦會作出)，基於有關目的，這些行為應列入調查階段 (fase da instrução) 內。

這個調查階段之目的是證明由當事人提出之事實。然而，關於書證 (prova documental)，第 450 條規定：“作為起訴 (acção) 或防禦 (辯護) 依據之證據之文書、應在主張事實時提出” (第 1 款)。

然而，亦可能在訴辯書狀階段內作出訴訟之調查行為。

例如：在訴辯書狀階段當中，當其中一方當事人對另一方當事人主張之事實不作出答辯時，會被視為自認之證據 (prova por confissão) (對事實有完全證明力 (prova plena))。這裏亦是一個列入書狀階段之預審行為 (證明行為)。

並非只在訴辯書狀階段內方有該些行為、而該些行為之目的與程序行進之其他各個階段之目的相一致。在辯論階段 (fase da discussão) (在口頭制度內，最重要的基本上是陳述，藉此律師分析及批評所舉出之證據，並將法律規範適用於事實上)，亦可按《民事訴訟法典》第 450 條第 2 款提出書證。

2.2. 清理及準備階段

(《民事訴訟法典》第 427 條至第 432 條)

分析了訴辯書狀後 (當事人提出其事實版本及所持之法律理由)，則出現簡縮階段。在這個階段，法官嘗試澄清當事人之要求及知道各人在訴訟內之法律狀況 (situação jurídica)。

並需審查有關訴訟案有否條件繼續 (由於當事人之立場已在訴辯書狀內界定，故較易審查)，倘有條件繼續進行，則從中剔除無用之事實 (factos inúteis)，界定被認定之事實 (matéria conhecida) 及將來要提出之證據。

這個階段之要素包括：

- (1)清理前批示 (Despacho pré-saneador 第 427 條)；
- (2)試行調解 (第 428 條)
- (3)清理批示 (despacho saneador 第 429 條)；
- (4)選擇事實事宜 (第 430 條)。

2.3. 調查階段 (fase da instrução 第 433 至 548 條)

接著是調查階段，如上所述，對於這個階段內各個行為所謀求之目的而言，

並無一個完全邏輯自主性，目的是：證明由當事人陳述之事實。

預審階段可包括在任何其他階段皆可提出之不同證據：鑑定 (arbitramento)，司法鑑定、透過請求書進行詢問證人 (inquirição de testemunhas por carta precatória) 等。

在預審階段中這些證據方法 (meios de prova) 可以稱為具有自主性的，最低限度按時間順序標準而言是可作具體化。

2.4. 辯論及審判階段 (fase da discussão e julgamento 第 549 至 560 條)

辯論階段通常屬於辯論及審判聽證階段 (**audiência de discussão e julgamento**)，過去學理稱此為“一般聽證” (audiência geral)，必須由合議庭作出 (第 549 條第 1 款)。

無論在聽證之前或在聽證 (audiência) 期間，辯論之目的是決定那些為既證之事實 (factos provados)。雙方當事人之律師作出對各種證據分析及批評，在陳述裏將法律規範適用於事實，作出請求理由成立或不成立為結論⁶。

而對案件法律問題之辯論，可以口頭方式或書面方式進行 (第 560 條)。

稍後我們再探討這個內容。

按上述規定，在辯論階段，還可提出先前無提出之書證 (prova documental) (第 450 條第 2 款)。

在本階段內法院審理有關問題及對爭訟作出判決。

在審判裏，應區分事實審 (julgamento de facto) 與法律審 (julgamento de direito)。

(1) 事實審：在宣告之訴裏之通常程序內，事實審可以由主案法官 (juiz do processo) 負責。

例被告人無作出答辯，按照第 405 條 (第 1 款) 之規定：“由原告人分條縷述之事實視為自認”。卷宗先供原告人之律師閱覽，之後是被告人之律師，為期 10 天，以便作出書面陳述，之後作出審判，及按適用之法律而作出判決 (第 2 款)。

從這條條文中可得知，在這些情況下，事實審及法律審由主案法官負責。

然而作為通則，按照《民事訴訟法典》第 549 條第 1 款之規定，在宣告之訴裏之通常訴訟程序中，事實審由合議庭 (tribunal colectivo) 負責。

合議庭只按其心證審理事實。連同劃定事實之合議庭裁判 (acórdão)，將案送交主案法官作出判決，以便進行法律審。

(2) 法律審：通則是由合議庭主席 (presidente do tribunal colectivo) 負責。

第 405 條所述之缺席應訊之情況下，法律審由獨任法官負責，他是主案法官。

⁶ 陳述之順序是：先由原告人之律師作出陳述，接著是被告人之律師。

第二節 訴辯書狀階段 (fase dos articulados)

3. 訴辯書狀的概念 (Noção de articulados)

第一百零一條 (訴辯書狀之定義)

一、訴辯書狀係指當事人闡述訴訟及防禦之依據以及提出相關請求之文書。

二、在訴訟、其附隨事項及保全程序中，凡有助說明請求或防禦之依據之事實，必須以分條縷述之形式敘述；但不影響法律免除以分條縷述形式敘述之情況。

首先需指出訴辯書狀之重要性，此為最難製作之司法文書。

古語有云：“誰願意，誰主張，但只有誰掌握、方懂作成訴辯書狀”。為此，訴辯書狀是律師的基礎，因可憑此份文書判斷其履行職務之能力，尤其是絕大程度決定了“訴之命運”及由其負責之對利益之確保。

簡單 (simplicidade)、**精確** (concisão) 及 **清楚** (clareza) 乃訴辯書狀之關鍵。對事實之闡述及法律之指明應準確，避免語言過贅及重覆。法律理由及請求應用清楚及無疑之方式提出。

但不幸的是我們所見的訴辯書狀往往相反：疑問多及難以理解。或所提出之請求叫人難明、或用巧用語言而瞞騙事實。

故法律有理由確立了 **起訴狀不適當這個概念** (《民事訴訟法典》第 139 條)，這些瑕疵可產生一個 **程序無效** (nulidade processual)。

4. 起訴狀 (petição inicial)

在一般訴辯書狀中，特別重要的是 **起訴狀**，其缺點可影響訴之結果。

起訴狀 是首份訴辯書狀——原告人透過這份書狀提出其主張 (pretensão)，即其請求 (pedido)。

4.1. 起訴狀之組成部份

可將起訴狀分成四部分，其內容見載於第 389 條第 1 款之各項內，計有：地址，抬頭 (稱為開首)，斜述 (narração)，結論 (conclusão)。還應包括補充性指示：

在地址內要識別法院——第 389 條第 1 款 a 項。

抬頭 (introito) 包括：

a) 當事人之身分資料 (第 389 條第 1 款 a 項)，

b) 指明 **訴訟形式** (forma de processo) (第 389 條第 1 款 b 項)。

當事人身分資料之識別是指：姓名、職業及地址。之後要指出 **訴訟形式**：**普通** 或 **特別訴訟程序**，倘屬後者，還需指出類別。

第 389 條第 1 款 c 項所指之敘述乃指 **事實及法律理由之陳述**，以此作為訴之依據。

按第 389 條第 1 款 d 項之規定，起訴狀之結論是指提出**請求** (pedido)。
除了這些重點外，起訴狀還應包括某些補充性指示：
指出訴之利益值（《民事訴訟法典》第 389 條第 1 款 e 項及第 247 及第 256 條）。
指明附交之文件及授權書 (procuração)；
律師之簽字及指出其住所或辦事處地址。

4.2. 一份起訴狀之圖例

（抬頭）

澳門初級法院法官

António da Silva，居於……，現訴 Manuel Lopes，所有權人，居於……

現提起本通常訴訟程序之給付之訴，依據如下：

（敘述）

1°-

原告人於一月十日將一傢具售予被告人，價格訂澳門幣為六萬元正。

2°-

一如《民法典》第 875 條第 2 款所規定般，應於三十天期內支付價金。

3°-

但被告人並無支付。

4°-

為此，按《民法典》第 877 條之規定，原告人有權要求支付。

（請求）

5°-

故應裁定本訴理由成立及判被告人向原告人支付六萬元澳門幣，並承擔有關訴訟費及司法費用。

（結論）

為此，請閣下傳喚被告人於法定期內答辯。

訴訟之利益值：MOP\$60,000.00（六萬元澳門幣）。

附：（……）文件，委托書及複本兩份。

律師辦事處位於……

_____（簽署）

但值得澄清這個例子之某些要點：

1°-) A 及 R.為原告人及被告人之簡寫。在結尾時用“D.e A.”，表示“分發及編成卷宗”。

2°-) 請求判被告人支付澳門幣六萬元及訴訟費及司法費用。我們看看這句話：

訴訟費 (custas)：按《民事訴訟法典》第 376 條之規定，對訴、或其隨隨事

項、或上訴作出審判之裁判，會判引發起訴之當事人支付訴訟費用。相同之規則亦見於《法院訴訟費用制度》（法令第 63/99/M 號，十月廿五日）。

故請求判處支付訴訟費用多餘。但慣常如此請求。

Procuradoria：是指《訴訟費用制度》：法官必須判予勝訴方一筆律師費（法院代理人之費用）。

亦無需請求判支付予法院代理人費用，但習慣上會如此請求。

3°-) 在起訴狀尾部指明附上之文件，是指作為證明訴之依據之文件，連同訴辯書狀一併提交，以證明主張之事實，否則可於後來提交，但會被科處罰款，證明不能連同訴辯書狀一併提交則除外。此為第 450 條第 1 款之規定。

4°-) 訴訟之複本（第 102 條第 1 款）——須遵守《民事訴訟法典》（CPC）第 102 條各款之規定。

5. 請求之類型（modalidade do pedido）

請求——指原告人在起訴狀請求之司法保護措施，通常是肯定（certo）、確定（fixo）、到期（vencido）及獨一（único）。

但請求可例外地屬於：

非確定（não fixo），而是選擇性的 alternativo；

非肯定（não certo），而是概括性的（genérico）；

未到期（não vencido），而是將到期的（prestação vincenda）；

非獨一（não único），而多項的 multiplo。

5.1. 擇一請求

擇一請求之事宜見規範在《民事訴訟法典》第 390 條內。

通常所提出之請求體現在要求一個司法保護措施，目的是承認或實行某個積極法律狀況。

在其他情況下，則分別地請求兩個或多個措施：這就是擇一請求⁷。

這種選擇性，作為司法請求之特點，在第 390 條所定之情況則會出現（由爭議法律關係產生）；或原告人提出個請求（主請求），倘該主請求理由不成立，則提出另一個請求（補充請求）。後者從屬於前者。

按照第 390 條之規定，這種選擇性可出現在兩種情況：

選擇之債；

變成選擇之債之債務。

5.1.1. 選擇之債（obrigações alternativas）

這類債見規範在《民法典》第 536 條至第 542 條內。

⁷ 應區分擇一請求與合併請求。合併請求是：向法院請求多個措施，不採取一種措施不會引致不能採取其他；擇一請求是指：同時請求多項措施，倘採取其中一個措施，則不會採取其他。

如眾所知，對債客體（標的）之選擇可屬於債權人、債務人或第三人。

倘屬於債權人，則不會有選擇性請求：債權人一開始便可行使其選擇權⁸。

倘由債務人選擇，則請求可以選擇性方式提出。倘不屬這種情況，作出一個選擇性給付判決仍不足夠（第 390 條第 2 款）。在執行上，按《民事訴訟法典》第 687 條之規定，先作出選擇。

倘選擇屬第三人（民法典第 542 條），不存在選擇性請求。原告人須按第 208 條所定之（訴訟以外通知）通知第三人（notificação avulsa），以便後者作出選擇。倘作出這種通知，則第 390 條第 2 款及第 687 條類推適用。

注意，這一些選擇請求的形式是否可以適用至債務人在具體個案中可以作出選擇，是來源於債本身之性質。

5.1.2. 選擇性給付之債

選擇性給付之債分別指源自雙務合同（contrato sinalagmático）之債及事實給付之債。

這類債之特點是來自不履行先前之給付。換言之，有一個簡單之債（而非選擇之債），因為一個變更性事實而轉為選擇之債：債務遲延。自債務人遲延之時起、債務轉為選擇之債⁹（pedidos alternativos）。

分析《民法典》第 422 及第 423 條所定之情況（不履行雙務合同之債），我們知道：

不履行一由雙務合同所生之債務時，債權人有權選擇性地：

解除自己本身之債務；

循司法途徑要求債務人履行債務；

要求一筆損害賠償（《民法典》第 787 條）。

不履行一事實給付時、債權人有選擇性地（《民事訴訟法典》第 826 條及《民法典》第 818 條）：

由第三人作出給付，而開支，則由債務人承擔；

要求一筆損害賠償（《民法典》第 793 條第 1 款）。

無論是 a 項或 b 項之情況，按照第 390 條第 1 款之規定，可出現請求之選擇性。

然而，倘原告人提出一個請求，預計該請求之理由會不成立，故提出另一個補充請求（pedido subsidiário），但只在主請求理由不足時才考慮後述之請求（第 390 條）。

我們假設下述例子：

A 透過遺囑將一房屋遺贈予 B。但遺贈條款（cláusula do legado）存有疑問，無清楚指明遺贈之標的是該房屋之**完全所有權**（propriedade perfeita）或僅是房屋

⁸ 倘不作出選擇，而作出一個選擇性請求，應視為原告人放棄選擇之請求，則改為由被告作出選擇。見註腳四所述之作品，第 127 至 128 頁。

⁹ 須記起債法之知識。

之用益權（usufruto）。

受贈人（legatário）提起一訴、以實行其權利，請求承認其在遺贈中獲得完全所有權，或，倘不作如此理解，則承認其對房屋之用益權。

請求之間之敵對性並無不會阻止依第 390 條第 3 款提出這種請求，但阻止原告人與被告人合併（coligação）之情況則阻止這種情況。

5.2. 概括性請求（pedido genérico）

請求之另一個正常特點是肯定。

但請求往往可以是**概括性請求**，即其量為不確定、或有一個整體確定之標的，而非特定指明其組成單元（unidades constitutivas）。

1876 年之《民事訴訟法典》容許自由地提出**概括性請求**。原告人可自由地提出**概括性請求**，留待稍後具體落實這個請求。

根據現行《民事訴訟法典》第 392 條第 1 款規定：“在下述情況下可提出**概括性請求**：

倘訴之間接標的為事實或權利之集合物；

倘仍未能確定地決定不法事實之後果，又或受害人欲行使《民法典》第 563 條賦予之權能；“倘量之訂定取決於帳目之提交或由被告人作出之另一個行為。”

在提出概括性請求後會發生什麼事？

可在判決之前，透過結算之附隨事項（incidente de liquidação）而結算請求（第 308 至第 310 條）。原訴仿如折成兩個訴訟、一個是**主訴**（ação principal），另一個為**附訴**（附隨訴訟）（ação incidental），後者之目的是使概括性請求折成**特定請求**（pedido específico），附訴與主訴同時進行。倘未能在判決前結算，且有意提起執行之訴，須考慮第 686 條及第 689 至 694 條。

我們現在分析第 392 條所述之例子：指可提出**概括請求**之例子。

1) 倘訴之間接標的為事實或權利之集合物（universalidade de facto ou de direito）

可用一簡單例子說明這一款所定之情況。

A 請求 B 交付一群羊或一間圖書館。並非在請求內指出每隻羊或每本書，而是請求整群或整個集合物，故提出交付**事實集合物**（universalidade de facto）之請求。

2) 倘仍未能肯定地確定地不法事實之後果（consequências do facto ilícito）

通常以第 392 第 1 款 b 項條為基礎，在**損害賠償之訴**（ações de indemnização por danos）內提出**概括性請求**。

例子：

某人是一宗交通意外之受害人。在由意外而引致之患病期間，針對引起意外之各人提出一訴訟，請求判其支付所欠之賠償。但患病情況仍未結束，故只有按上述方式作出結算。

仍未知道意外之確定性後果

3) 倘量之訂定取決於帳目之提交 (prestação de contas) 或由被告人作出另一個行為

第 392 條第 1 款 c 項再細分成兩個細之假設情況——值得對其分外加以分析。

第一種情況：量之訂定取決於帳目之提交。

帳目提交之特別程序 (processo especial) 見規範在第 879 條至第 889 條。從這些規範中可得知，只有提交及審核帳目後，原告人方知道其有權得到之量 (額)，為此，在此之前，只能提出**概括性請求**。

第二種情況：量之訂定取決於另外一個應由被告人作出之行為。

例如：在執行**事實給付**之情況下。倘無作出事實給付，原告人可要求損害賠償。這個請求須為概括性，因為只有事實作出後才可結算因不履行而產生之損害 (《民事訴訟法典》第 826 條及續後各條)。

現在我們有系統地看看第 392 條所述之全部情況，如何指明概括性請求。

可有多種形式：

在第 392 條第 1 款 c 項所述之情況下，**結算**自動進行：透過帳目之給付或被告人作出之另外一個事實而進行。倘不提交帳目或不作出另外一個行為，法律容許循法途徑代替這個被告人不作出之事實。

在第 392 條第 1 款 a 及 b 項所述之情況下，**結算**按下述方式進行：

在宣告之訴內，透過**結算之附隨事項**進行。此為正常之方法：見第 392 條第 2 款，第 308 條至第 310 條。

透過結算作為**執行之訴**之前奏 (倘上述方法不可能) ——第 686 及 689 至 694 條。

將來到期之給付之請求 (pedidos de prestações vincendas)

將來到期之債務之請求，乃正常制度之偏差 (desvios)，因為正常制度要求請求所指之債務必須已到期 (obrigação vencida)。

第 393 條提及此制度。

“1. 請求作出將到期之給付

一、如屬定期作出之給付，而債務人不履行，則請求中得包括已到期之給付，以及債務維持期間將到期之給付。

二、如欲在租賃結束時即能勒令承租人遷出一房地產，以及遇有在給付到期之日不具執行名義將會對債權人造成嚴重損失此等類似情況，亦得請求就將來之給付作出判處。”

這種請求之特別形式體現在下述之假設情況：

A 針對 B 提出一給付之訴，請求判 B 向其支付一租予被告人之房屋之租金。

倘無第 393 條第 1 款之規範，即使該訴會被裁定理由成立，但在將來，每次 B 不支付租金，須要再提起一次訴訟，才可以提起**執行程序**。

然第 393 條第 1 款容許 A 在請求內包括所欠之債之給付，還可包括將來到

期、且不會履行之債。

以這種方式提出請求後，倘訴被裁定理由成立、原告人會獲得一份連貫性執行判決¹⁰，容許在同一程序內更新程序以支付稍後到期之給付（第 565 條及第 814 條第 1 款）。

第 393 條第 2 款規範可請求將來到期之債之兩種情況：

租賃間到勒遷；

倘在到期日仍無執行名譽，可對債權人造成嚴重損害。

最後必須注意：在解釋時須將《民事訴訟法典》第 393 條同第 565 條結合。

（IV）

數個請求（pedidos múltiplos）

《民事訴訟法典》第 391 條第 1 款規定：

“一、原告得於同一訴訟程序中，針對同一被告一併提出數個請求，只要各請求係相容者，且無出現第六十五條所指之障礙。”

除了提出單一請求（pedido único）外，法律亦容許將**請求合併**（cumulação de pedidos）——由數個或合併之請求形式。

然第 391 條規定**客體合併**（cumulação objectiva）取決於某些要件之成就：

所有請求皆遵從同一**訴訟形式**（forma de processo），除非**形式**不同乃因訴額（利益值）之不同所致；

必須在事宜或等級上同一法院有管轄權限審理所提出之全部請求。

除了這兩個**形式**或**程序性質**之要件外，法律亦要求需符合一個**實質要件**：各合併之請求之間無矛盾（參閱第 391 條第 1 款，第 139 條第 2 款 c 項，第 394 條第 1 款 a 項）。

還需指出，合併可以是同類之請求，或一個或多個**主請求**與一個或多個**附從請求**（pedidos acessórios）合併。

假設 A 在不同時間向 B 締結了多項債務，而 A 無支付這些債務。B 可以這些債務之給付請求合併，只需符合第 391 條之各個要件則可。在此情況下，所有請求皆有相同之等級。

假設在同一訴內 A 請求**本金及利息**，或請求宣告一合同無效及返還已作之給付，或請求交付一房地產及其收益；則其中一個請求是**補充請求**，是另一個請求之延續（參閱第 273 條第 2 款）：屬於主請求，（要求交付本金，請求宣告無效，請求交付一房地產）；屬於附從請求（支付利息、因合同無效而返還已作之給付，交付房地產之收入）。

6. 提起訴訟

現在我們談談起訴。

¹⁰ “具連續性效應之判決”是指判決發生連續性效果；而 sentença de “execução aparelhada”是指：以同一判決為基礎，可提出多項執行。

第 211 條規定：

“一、訴訟程序自提起訴訟時開始；辦事處一旦收到有關起訴狀，訴訟即視為已提起及正待決，但不影響第一百條規定之適用。

二、然而，提起訴訟之行為僅自傳喚時起方對被告產生效力，但法律另有規定者除外。”將起訴狀交到法院辦事處後，倘被收取，則立即在有關紀錄冊上登記。

起訴狀之登記設定了入案之日期，即訴、程序之開始。

7. 分發 (distribuição)

將案件進行分發，目的是平均分配法院之工作，指定訴訟進行所在之分庭或科（《民事訴訟法典》第 155 條）。

按案件類別進行分發。每一類訴訟相當於一類案。關於這點，值得閱讀《民事訴訟法典》第 161 條之規定。

透過《民事訴訟法典》第 157 條可知：每逢週一及週四下午二時進行案件分發，由負責分發之法官主持。倘週一及週四為公假，則於續後之首個工作天進行（第 157 條第 2 款）。

分發 (distribuição) 後，起訴狀則交到所屬之科（分庭），由其作出紀錄及編成卷宗。

編制卷宗 (autuação) 是指組織卷宗，用線訂裝及附上有法院名稱之封面，指明法院、科（分庭）、訴額（利益值）、案件類別、原告人及被告人之姓名等。

8. 預付金 (perparo inicial)

至此我們有五個不同之行為：

由原告人將起訴狀交到法院辦事處；

在辦事處記錄起訴狀；

分發；

在訴訟進行所在之分庭內記錄；

編成卷宗。

接著繳交**預先訴訟費**。

按照一個概括性之概念，預付訴訟費是指作出某特定程序活動之前繳交之費用，當事人必須存放這些款、以作為支付司法費用 (despesas judiciais) 之保證金。

預付費並非一種付款；預付費是一種保證金 (caução)。並非支付已作出之開支，而是作為即將作出開支之保證金。

《法院訴訟費用制度》（法令第 63/99/M 號，十月廿五日）區分**最初預付金** (preparos iniciais)、**開支預付金** (preparos para despesas) 及**審判預付金** (preparos para julgamento)。

預付金是在任何須支付司法費用的程序、上訴或附隨事項開始前支付之費

用。

向法院提交起訴狀後、或分發後十天內支付**預付費**。

倘原告人無在法定期內支付預付費用，將會被通知在十天內繳交預付費、並附加與預付金相同金額之**司法費用**（taxa de justiça）。

當原告或保全措施的申請人又或聲請執行人到期不支付預付金，除了須支付罰款外還會使到有關效力在未支付前不會產生。

預付金按訴訟進行所在之科發出之憑證（guias）存入有關帳戶。

9. 初端批示（despacho liminar）

接著會將卷宗送交法官、以便作出**初端批示**。按照《民事訴訟法典》第 394 條、第 397 條及第 398 條之規定，這種批示基本上分三類。

法官應在十天內作出這類批示，自將卷宗送交其時起計算（《民事訴訟法典》第 100 條第 1 款）。

現在我們看看**初端批示**之幾種形式：

- 駁回批示（消極）；
- 補正批示（或邀請批示）；
- 傳喚批示（積極）。

10. 駁回批示（despacho de indeferimento）

這個批示確定後，訴訟法律關係或訴訟程序則會消滅。

第 394 條規定：當出現下述情況，應初端駁回訴狀：

起訴狀不當；

按第 15 條及續後數條的規定，有關訴訟明顯不可向澳門法院提起時；

明顯欠缺當事人之訴訟前提：當事人能力或不具正當性，又或明顯無訴之利益；

訴權之除斥期明顯已過；

訴之理由明顯不能成立。

現在我們看看每一種瑕疵。

10.1. 起訴狀不當（ineptidão da petição inicial）

第 139 條第 2 款指出：起訴狀不當：

- a) 請求或訴因未有指明或含糊不清；
- b) 請求與訴因相互矛盾；
- c) 同時載有實質上互不相容之訴因或請求。

澳門法院無管轄權

參閱第 15 至 20 條的規定以及本教材第一卷之有關內容。

10.3. 明顯欠缺訴訟前提 (falta manifesta de pressupostos processuais)

原告人或被告人欠缺當事人能力 (personalidade judiciária) 或無正當性又或欠缺訴之利益屬明顯時令引致作出**初端駁回批示**。

在關於當事人之訴訟前提之中，只是欠缺法院代理 (倘屬於強制性)，並不會引致**初端駁回**，只引致《民事訴訟法典》第 75 條之後果。

10.4. 起訴之除斥期間明顯已過

倘訴明顯是在期間過後才提起，則應作出**初端駁回之批示**。

某些訴應在一定期間內提起，例**母子關係調查之訴** (acções de investigação de maternidade)，通則是任何時間均可提起訴訟 (民法典第 1677 條第 1 款)，但若兒子已死亡時，僅可由其配偶或卑親屬在其死亡之日起計一年之內提起訴訟 (第 1677 條第 2 款)。

倘某些權利人在除斥期後 (expirado o prazo de caducidade) 才行使其權利，法官應**初端駁回起訴**。

引致初端駁回的是**訴權之失效** (caducidade do direito de acção)，而非附屬之實體權利之**時效**已過 (prescrição do direito material subjacente)。

倘屬於**時效**，法官不得初端駁回起訴狀，因為法院不得依職權審理**時效**的問題。此為源自《民法典》第 296 條第 1 款之規定。在此情況下，法官無理由初端駁回，只可命令傳喚被告，其如欲抗辯，可提出抗辯 (當然只是一種負擔)，指出原告主張之實體權利之時效已過。

10.5. 訴之理由明顯不成立 (impossibilidade evidente de procedência da acção)

還有第 394 條第 1 款 e 項所述之其他情況，其中應初端駁回訴狀：“**當原告人之主張明顯不成立時**”。

我們已知道法官要考慮訴之內容，審定原告人之請求及如何提出其請求。這種審定某種程度上指出訴是否理由成立，因為法律上不能，因為不能再繼續，在此情況下，應**初端駁回起訴狀**。

以民法不容許之一個依據學理由 (無載於《民法典》第 1635 條及續後數條) 而提出爭訟離婚 (divórcio litigioso)。

應初端駁回該起訴狀，因起訴明顯不可行。

10.6. 第 394 條第 2 款容許作出局部初端駁回 (indeferimento liminar parcial)，條件是部份初端駁回導致任一個被告退出有關訴訟

但需小心解釋這條規定：局部駁回只可在第 394 條第 1 款所述之情況下作出。

倘針對多個被告人而提出一個請求 (請求)，而其中一人明顯無正當性 (ilegitimidade)，對於請求判處該人之部分，法官可以初端駁回起訴狀。

然而，在**請求合併** (cumulação de pedidos) 之情況下，即使部份駁回不能使

任何被告退出，似乎仍可作出部份駁回：法官應審查是否其中一些請求理由不成立，而駁回該請求（rejeitar este pedido）。

換言之：在數個請求或合併請求之情況下，可對其中一個請求作出初端駁回，即使並非引致排除任何被告亦然。只在單獨請求（pedido único）之情況下，方適用第 394 條第 2 款。

10.7. 還需考慮第 394 條第 3 款之規定

“三、如原告選擇之訴訟形式與訴訟之性質或利益值不相對應，則命令採用適當之形式；然而，對於此種訴訟形式如不能採用有關起訴狀者，則駁回該起訴狀”。

補充這條範的是第 145 條。

10.8. 駁回批示之通知

倘起訴狀被初端駁回，遵守《民事訴訟法典》第 200 條及第 207 條之規定，應將駁回批示通知原告。

原告人可採取下述其中一種立場：

同意駁回批示：

在此情況下，因批示內所作之審判而消滅訴訟關係（第 229 條 a 項）。

在十天期內提交新之起訴狀（第 396 條第 1 款）

在此情況下，訴自首份訴狀交到法院辦事處之日為已提起，此對法律所定之訴權之除斥期（prazos de caducidade）十分重要（第 396 條第 2 款）；

(3) 按第 395 條第 1 款之規定，對駁回批示提起上訴（Recorre do despacho de indeferimento）。

在此情況下，為上訴及本訴之效力，應傳喚被告（第 395 條第 3 款）。

倘上訴被裁定為理由成立，該程序則繼續；倘駁回之批示被確認，原告人有權在十天期內提交一份新訴狀，自卷宗送回第一審法院之日起計（第 395 條第 4 款及第 396 條第 1 款）。倘無在該期間提出，則訴訟關係消滅。

11. 補正批示（despacho de aperfeiçoamento）

在補正批示內，要考慮起訴狀內之缺點，而這些缺點之嚴重性不足以引致駁回起訴，在此情況下，法官可命令原告人補正這些缺點。

第 397 條規定如下：

一、第三百九十四條第一款所指之任一情況雖無出現，但因起訴狀欠缺法定要件或未附具必需之文件，以致不能繼續獲處理，又或在闡述所指稱之事實事宜方面有不足或不準確之處者，得請原告更正或補充起訴狀之內容，或提交欠缺之文件，並為此定出限期。

二、如新起訴狀或欠缺之文件於所定之期間內提交，則適用上條第二款之規定；如主持分發工作之法官拒絕接納起訴狀，只要原告提交另一起訴狀，而該

起訴狀在隨後第一次分發中獲接納者，亦適用上述制度。

三、對第一款所指之批示不得提起上訴。

這條規範規定了哪些缺點或不當情事（不規則性）？

欠缺法定要件（falta de requisitos legais）

例無指出訴訟之利益值（valor de causa）（行政辦事處在接收起訴狀時無發現）。倘無指出訴訟的利益值，法官可以不駁回起訴，按照第 397 條之規定，指定一個期間，要求當事人指出該金額。

欠缺提交文件（falta de apresentação de documentos）

假設在訴狀內，提起主張所有權、或不動產之佔有之訴（acção de posse），而無提交有關文件；或提起一追討債務及利息之訴，但無提交證明文件。

在此情況下，法官可命令提交有關文件（關於第一種情況，見第 280 條）。

在陳述事實事宜方面之不足：

例無指出請求理由成立所需之事實。

假設以嚴重侮辱為依據而提起離婚之訴，但無在訴狀內明示地指出這些侮辱。倘不認定這些侮辱事實，法官不得作成相關之未證事實。

按照第 397 條之規定，在所有這些情況下，法官可以邀請原告人填補有關欠缺之要件、或有關缺點。

但按照該條文第 2 款最後部分之規定，原告人是否需要提出一份新之訴狀？

有人認為無此必要，原告人只需提出一份額外訴狀，補正原先之訴狀則可；將**補正之批示**制度（第 397 條）與**駁回之批示**（第 394 條）制度相比較，可發現有一個重要不同之處；按第 394 條之規定，倘符合規定，法官應作出**駁回批示**，而第 397 條則給予法官作出**補正批示**之權能，只要出現該規範所定之任一種情況則可。換言之，有別於駁回批示，**補正批示**並非法官之義務，而是法官之權力。

這個特點還反映在法官規定**補正訴狀**之期間，而按照第 396 條之規定，法律所定之作出**駁回批示**之期間為十天。

由此產生下述問題：可否就**補正批示**提出上訴？因為法律並無述及此點。

似乎答案是否定，依據如下：

從前，舊《民事訴訟法典》第 679 條第 1 款規定：

不得就一般日常批示及行使自由裁量權之批示提起上訴。

而補正批示乃行使一個法定裁量權而作出，按照第 477 條第 1 款之規定“……可以邀請原告人……”。

為此，按照第 679 條第 1 款之規定，不接受對此批示（補正批示）提起上訴。

而新法典第 397 條第 3 款明確規定“對第 1 款所指的批示不得提起上訴。”

然而，倘原告人不履行**補正批示**又如何？

要考慮幾種假設情況：

因無指明訴訟之利益值作出這個批示：訴訟關係消滅。

作出這個批示目的是補正起訴狀之缺點：指定期間過後，法官須命令傳喚

被告人，倘訴被裁定為理由不足，則原告人只能怪自己。

有人認為法官可合法之拒絕起訴狀，倘批示無被遵守¹¹，然似乎不能接受這個意見，因為“只在無出現第 374 條第 1 款所定之情況方能作出**補正批示**”（397 條）。

除了命令傳喚被告人外，別無其他方法。倘不具備駁回起訴狀之條件，則不能駁回起訴狀。

12. 傳喚批示（despacho de citação）

除了上文所述之兩種形式外（**駁回批示**及**補正批示**），**初端批示**還可以是**傳喚批示**。此為常見之情況。

述及**傳喚批示**之第 398 條規定：

“一、如無**初端駁回起訴狀之理由**，且起訴狀具條件繼續獲處理，則命令傳喚被告。”。

只有案卷分發及支付最初預付金後方可傳喚被告人。然而，法律容許作出**提前傳喚**，（citação prévia）將傳喚這個時間提前。

第 398 條第 2 款規定了**提前傳喚**：

“二、如不應作出**公示傳喚**，而原告聲請於案件分發前作出傳喚，且法官經考慮所提出之理由，認為分發前作傳喚屬合理者，則於分發前作傳喚；在此情況下，須立即將起訴狀提交法官作批示；如命令先作傳喚，則於傳喚後進行分發。”

由此規範可得知，原告人有權能申請**提前傳喚**，並指出有關理由。

原因何在？

傳喚發生第 401 條所述之效果——稍後我們會述及。

其中一個是民法典第 315 條 a 項：**中斷時效**（interromper a prescrição）。

倘在時效期消滅期間提起訴訟，在該期間完成前傳喚被告人，對原告人有很大利益。

在**起訴**（第 211 條）與**傳喚**這段期間內，倘不容許提前傳喚，則發生時效所需之期間會到：分發、預付訴訟費、送檢（conclusão）、初端批示，傳喚狀、傳喚——此為需時之行為。

為了避免遲延，在上述情況下，可聲請**提前傳喚**，只要有充足理由則可。

倘作出提前傳喚之命令，只有傳喚被告人後才將案卷分發，分發後作出我們已學習之行為，但已非作出初端批示，因為法官先前命令傳喚時已作出。

按第 399 條第 1 款之規定，不得對傳喚批示提出上訴。

同一條文第 2 款規定：

“二、命令傳喚之批示對可作為**初端駁回起訴狀之原因之問題**所採取之**解決辦法非屬確定性**”。

¹¹ 見由最高法院大法官 Lopes Cardoso 著之《民事訴訟法典評釋》，第二版，第 352 頁。

因為這條規範，即使傳喚批示轉為確定，在答辯時，被告人可提出任何第 394 條所述之問題（起訴狀不適格、不符合前提等），此種種皆會引致駁回訴狀。法官需受理這些問題，通常在作成**清理批示**時受理。

13. 傳喚被告人

13.1. 傳喚之概念

一如第 175 條第 1 款 a 項規定般，傳喚是“知會被告其被某人起訴並召喚其參與訴訟以作出防禦之行為”。

傳喚之重要性十分大：它是產生第 401 條效果之重心（除其他外）。

現在我們看看傳喚之環節。

在作出實質傳喚之時，有一個時間決定傳喚行為所使用之方法之（此為傳喚批示之標的就是傳喚行為）。

第 126 條及隨後數條規範了訴訟行為告知之事宜：

第一百二十六條（方式）“一、請求作出需澳門以外地方之法院或其他當局參與之訴訟行為時，須使用請求書，但適用於澳門之國際協約或屬司法協助領域之協定另有規定者除外。

二、法院命令在職務上從屬於法院之實體執行訴訟行為時，須使用命令狀。

三、請求提供資料、送交文件或實行按性質無須法院部門參與之行為時，須以公函或其他通訊方法，向被請求協助之公共或私人實體直接提出。

四、法院部門除採用郵遞方式外，亦得按制定施行細則之法規之規定，以圖文傳真及遠距離資訊傳送方法，以及電報、電話通訊或其他快捷及安全之通訊方法，傳遞任何信息。”

專指傳喚行為的條文在 176 至 179 條及 189 至 199 條。

13.2. 傳喚方式（formas de citação）

關於傳喚方式，需要考慮下述方式：

——向本人傳喚傳喚（第 175 條第 1 款 a 項及第 180 條第 1 及第 2 款）；

——對被傳喚人以外之另一人作出傳喚（第 176 條）；

——在傳喚人住所留下通知之傳喚（第 186 條第 3 款）；

——郵遞傳喚（citação postal）（第 182 條）；

——公示傳喚（citação edital）（第 180 條第 1 及第 6 款以及第 194 至 199 條）。

所述之方式詳細地規範在《民事訴訟法典》第 180 條及續後內，原因在於傳喚行為所產生之重要法律效果。

在分析這些效果之前，我們先看看被告人作出防禦（辯護）之負擔（ókus）之期間。

這個期間自傳喚起計算。在作出傳喚時，應指出被告人可作出防禦（辯護）之期間（在通常程序內，期間是三十天——見第 403 條第 1 款）。倘傳喚是在另一個法區作出、或在外國作出，正常之期間會較長。

將這個防禦期間延長稱為**延期**（dilação）。這個延長之額外期間，會因應通訊之距離及便利而有所不同，這些不同之期間分別在第 199 條第 1 款之幾項中指出。

14. 傳喚之效果（efeitos da citação）

傳喚（這個行為）之主要效果：

1. ——中止時效；
 2. ——終止佔有人之善意；
 3. ——倘屬於無特定期限之債務，使債務人遲延；
 4. ——確定訴之基本元素；
 5. ——阻止被告人提起一個審理相同法律關係之訴訟。
- 首三個效果是實體法之效果；最後兩個是程序法之效果。

現在我們逐項看看。

1) 中止時效（interrupção da prescrição）

解釋《民事訴訟法典》第 211 條第 2 款及民法典第 315 至 319 條之規定，可得知時效之中斷只是自對被告人作出傳喚方發生，而非自起訴之時。

2) 終止佔有人之善意（cessação da boa fé do possuidor）

這個傳喚效果載於《民事訴訟法典》第 401 條 a 項內。

第四百零一條（傳喚之效果） “除法律特別規定之效果外，傳喚亦產生下列效果：

- a) 使佔有人之善意終止；
- b) 按照第二百一十二條之規定，訴訟之基本要素維持不變；
- c) 被告不得針對原告提起旨在審理同一法律問題之訴訟。”

終止善意之重要性十分大：

“在善意佔有人知悉其占有係損害他人權利前所獲得之天然孳息及在此期限前所產生之法定孳息，歸該佔有人所有。”（《民法典》第 1195 條第 1 款）。

3) 倘債務無肯定期間，傳喚令債務人處於遲延狀況

倘屬於無特定期間之債務，則需**催告**債務人使債務到期。

催告（interpelação）是債權人向債務人作出之勒令行為，要求後者履行其債務。

其中一個催告方式是《民事訴訟法典》第 565 條第 3 款及第 688 條第 3 款傳喚。

4) 確定訴之基本要素

第 212 條規定：

傳喚被告後，訴訟程序在人、請求及訴因方面均應維持不變，但屬法律規定可改變之情況除外。

5) 阻止被告人提起訴原告人、具相同標的之訴

這個傳喚效果建基於對訴訟已繫屬（重行起訴）（litispendência）之考慮，作

為一種延訴抗辯 (excepção dilatória) (起訴抗辯) (第 413 條 j 項)。

重複提起一訴訟，而最先提出之訴仍在進行時，則出現訴訟已繫屬 (litispendência) (第 416 及第 417 條)。按第 418 條第 1 款之規定，**訴訟已繫屬**之抗辯應在第二個案中提出。

傳喚行為對隨後之行為十分重要。倘無作出傳喚，除訴狀外，所有隨後之行為皆為無效 (第 140 條 a 項)。

第 141 條規定了欠缺傳喚之情況。

可以出現有傳喚，但被視為無效 (citação nulo) 之情況，例 “遵守了基本手續、但無遵守法律規定之其他居先手續，(第 144 條第 1 款)。在此情況下，只有欠缺會損害被傳喚人之防禦方考慮這種爭辯 (第 144 條第 2 款)。

第一百四十四條

傳喚之無效

一、不遵守法定手續而實行之傳喚屬無效，但不影響第一百四十一條規定之適用。

二、就無效提出爭辯之期間為就答辯所指定之期間；然而，如屬公示傳喚或未指定作出防禦之期間者，得於被傳喚之人參與訴訟程序後作出首個行為時就無效提出爭辯。

三、如傳喚方面出現之不當情事為所指定之防禦期間較法律規定之期間為長，則應容許在所指定之期間內作出防禦行為；但原告已請求重新按規定傳喚被告者除外。

四、不遵守規則而作之傳喚可對被傳喚之人之防禦造成損害時，所提出之爭辯方予以考慮。

15. 被傳喚人可持之立場

傳喚被告人後 (假定屬於通常程序、且無延期)，有三十天期間供被告作出**答辯** (contestar) (第 403 條第 1 款)。被告人可持兩種立場：**不答辯**或**答辯**。

我們看看這兩種情況，基本上是指**被告人缺席** (revelia) 及被告人提出**反對** (oposição) 之情況。

倘被告人不作出防禦 (辯護) (defesa)，則不到庭 (revelia)。

不到庭這個制度載於《民事訴訟法典》第 404 至第 406 條內。

16. 不到庭 (revelia)

在該幾條條文內定之**缺席制度**是：

經適當傳喚之被告人無作出答辯，在這個制度內，還需區分兩種情況：

A - 被告人已被傳喚、但無作任何表示：完全不作為，無指定委托人，亦無介入程序，亦不答辯 (**絕對不到庭**) (revelia absoluta)；

B - 被告人已被傳喚，無答辯，但委托了法院代理人或參加了程序 (相對不到庭) (revelia relativa)。

可以提出這樣的問題：不提出反對之被告人，他指定法定代理有何好處？往往有其好處存在：被告人認為原告人分條縷述之事實屬於真實，故任由視為承認這些事實，因此不作出答辯，但另一方面，可以認為這些事實不會引致原告人欲得出之結論。為此委任律師，以便在陳述時主張該訴之理由不成立。

每類缺席之後果並不相同，我們可以知道：

絕對不到庭 (revelia absoluta)

倘屬於**絕對不到庭**，法院審查是否已按法定手續作出了傳喚，倘有不當情事 (irregularidades)，則命令再次傳喚 (第 404 條)。

可以明白到，為何在這個行為上法院需證實正規地作出傳喚，因為可能被告人根本不知道訴之存在。

相對不到庭 (revelia relativa)

在此情況下，無需特別小心上段所述之內容。被告人無答辯、但出庭：故知道訴之存在。為此，法院無需依職權受理傳喚之正規性問題：即使傳喚屬於無效亦然，倘被告人無主張這個無效，則視無效已被補正 (第 149 條)。

絕對不到庭與相對不到庭制度在效果方面之分別在於：在第一種情況下，法院依職權認定在傳喚時可能出現之不當情事 (不規則性)，在第二種情況下則無需如此作為。

但有兩個共同及重要之後果：對由原告人主張之事實視為自認 (factos confessados) (第 405 條第 1 款)，第 406 條所述之情況則除外；因而改變程序之正常進行。

只要屬於具**效力之缺席** (revelia operante)，則發生這些後果。

何謂具效力之缺席？

指曾作出對本人之傳喚或相等之傳喚，產生被告人自認原告人主張之事實及改變程序正常進行之效果之缺席情況 (絕對或相對缺席)。

被告人不作為乃因未作出對本人之傳喚或相等之傳喚而產生之**無效力之缺席** (revelia inoperante)，或缺席不發生其正常效果，因為法律作出了保留。

在宣告之訴裏之通常程序內，這種保留，載於第 406 條內，其中規定：不生缺席之正常效果：

a) 如有數名被告，而其中一人作出答辯，則對於答辯人提出爭執之事實不適用上條規定；

b) 被告或其中一名被告無行為能力，而案件涉及無行為能力處理之事宜；又或已向被告或其中一名被告作出公示傳喚，而其仍絕對不到庭；

c) 當事人之意願不足以產生其欲透過訴訟取得之法律效果；

d) 涉及須以文書證明之事實。

值得分析每一種情況：

a) 在通常程序內，倘有多名被告人，而其中一人答辯，對於被爭執之事實 (反駁之事實) 屬於無效力之缺席。

然而，在**通常訴訟程序**內，一個被告人之防禦，只在提出爭執之事實反駁之事實方面惠及答辯人。

然而，在**必要共同訴訟**（*litisconsórcio necessário*）之情況下，似乎應保留上述制度。在這些情況下，對所有利害關係人來說，有需要維持對爭訟之統一裁判，避免在某些情況下適用罰則，在其他情況下則不適用。

第 240 條第 2 款支持這種見解。

b) **第 405 條第 1 款之罰則亦不適用於無行為能力之被告只要屬於無能力範圍內之事實則不宜。**

後述之規定只不過是適用《民事訴訟法典》第 43 條第 2 款所定之原則。

c) **無答辯不會引致自認原告人主張之事實，倘當事人之意願不足以產生透過訴欲得之法律效果。**

這裏規定了人們所稱之**不可處分之法​​律關係**（*relações jurídicas indisponíveis*）；不屬當事人意志範圍之法​​律關係，例身分之訴（推翻（爭執）父親身分、調查父親或母親等之訴）。

在這類訴內，無答辯不引致自認由原告人主張之事實。

《民事訴訟法典》第 406 條 c 項與第 241 條第 1 款相一致。

d) **最後，需有書證之事實不會被視為自認。**

在宣告之訴裏之通常程序內，倘在效果方面將具效力之缺席分類，基本體現在：

第一：事實之自認：為此，宣告之訴裏之通常程序屬於“半不利效果”（*cominatório semi-pleno*）。

第二：改變程序之正常程序：程序之正常進行出現偏離。

對由原告人主張之事實一旦視為自認，法官應作出批示，宣告這些事實視為自認，同時命令按順序將卷宗供查閱，先是原告人之律師，之後是被告人之律師，各有十天時間，以便作出書面陳述。接著作出判決，接法律對該案作出審判。

這一切皆明示地載於第 405 條第 2 款。

留意：在此情況下，有別於常發生之情況，訴由獨任法官審理，無須合議庭參與。

不存在無效力之缺席之情況下，不會對程序之正常進行有任何影響。不會將有關事實視為自認，且程序仍繼續正常進行，供被告答辯之期間過後，進入作出清理批示之階段。

17. 答辯（*contestação*）

17.1. 辯論（*contraditório*）

是因為辯論原則而傳喚被告人（第 3 條第 1 款），或目的是使被告處於平等地位而作出防禦（倘他願意）。

第 409 條第 1 款指出：“所有防禦行為應於答辯中作出，但法律規定須獨立提出之附隨事項除外。”

法典談及以提出爭執進行答辯及以抗辯進行答辯（第 407 條），按第 101 條第 2 款之規定，須以條文式（分條縷述方式）提出。

17.2. 嗣後防禦（辯護）

第 403 條規定：“一、被告得於獲傳喚後三十日期間內答辯；如有中間期間，則答辯期間自中間期間終結時起開始進行”。

然而，從第 409 條規定得知，被告人有在答辯以外提出防禦之方法，以及其他在答辯後作出防禦的方法。

在某些情況下，法律容許被告人在答辯後才提出（第 409 條第 2 款）。

“二、答辯後僅得提出基於嗣後之事實之抗辯、附隨事項及防禦方法，或法律明文規定可在答辯後提出或應依職權審理之抗辯、附隨事項及防禦方法。”

哪些情況？

倘防禦是以嗣後事實為基礎；

倘法律明示容許在答辯後作出防禦；

倘被告人主張之事實、法律強制規定此為法院依職權受理之事實。

我們逐項分析。

17.2.1. 以嗣後事實為基礎之防禦

透過第 425 及第 426 條，我們知道：在答辯後，可用新之訴辯書狀提出嗣後事實。

嗣後事實指：

在答辯之後發生之事實；

雖在答辯之前發生，但只在答辯之後才為被告人知悉（第 425 條第 2 款）。

新之訴辯書狀須在事實發生後、或在被告人知悉後之十五天內提出（第 425 條第 3 款）。

被告人在嗣後書狀內提出之防禦（或辯護）稱為嗣後防禦（defesa/deferida）。

17.2.2. 法律明示容許在答辯後作出之防禦

例第 150 條第 2 款所定之情況，其中規定：“對於第一百四十條及第一百四十六條所規定之無效，如不應視為已獲補正者，得於訴訟程序之任何時刻提出爭辯”。

此為嗣後防禦之另一種情況。

17.2.3. 由法院依職權受理、且利於被告人之情勢

延訴抗辯事由（excepção dilatória）可由當事人提出，但按規定法院須依職權審理（認定）。

第 414 條規定：

“除非抗辯以違反排除管轄權之協議或案件原應由自願仲裁庭審理為由而

提出，否則所有延訴抗辯均應由法院依職權審理”。

同樣地，法院應依職權受理既判案之永久抗辯事由（*excepção peremptória*）（第 415 條）。

第四百一十五條

永久抗辯之審理

對於法律無規定須取決於利害關係人之意願而提出之永久抗辯，法院須依職權審理。

按第 409 條第 2 款之規定，即使當事人無提出任何抗辯事由，可於稍後提出。倘如此作為，則屬於嗣後防禦（辯護）。

17.3. 答辯期間。分立防禦

除了這些情況外，應在答辯內作出全部防禦（第 409 條第 1 款），故應自傳喚起計三十天期內提出（第 403 條第 1 款）。

現在看看部份分立提出防禦（辯護）之情況（在答辯期內）。

但這個規則有例外之情況：

a)-合理障礙¹²（*justo impedimento*）

第 95 條第 3 款規定：

“行為期間過後，作出行為之權利即消滅，但出現下條所規定之合理障礙者除外。”

第 96 條第 2 款規定：

“指稱存有合理障礙之當事人應立即提供有關證據；如法官認為確實存有障礙，且認為當事人於障礙解除後立即提出聲請，則經聽取他方當事人意見後，准許聲請人逾期作出行為。”

按第 96 條第 1 款之規定，合理障礙是指：“因不可歸責於當事人、其代理人或訴訟代理人之事由，以致未能及時作出行為者，為合理障礙”。

例被傳喚之人突然患重病，使其不能作出答辯。由於有合理障礙，故可延長辯護之期間。

b)-被告人為複數（*pluralidade de réus*）

倘有數名被告人，且在不同之日期作出傳喚，只在最後被傳喚之被告人之答辯期結束，各人之答辯期方結束。

此為第 403 條第 2 及 3 款之規定：

“二、如有數名被告，而各人之防禦期間於不同日期終結，則各被告得於最遲開始進行之期間終結前共同作出答辯或各自作出答辯。

三、如原告對其中一名未獲傳喚之被告撤回訴訟，或捨棄有關請求，須將撤回訴訟或捨棄請求一事通知仍未答辯之被告，而其答辯期間自該通知之日起算。”

倘首先被傳喚之被告人有第 403 條給予之三十天答辯期，但這個期間、由

¹² 注意：合理障礙適用於所有期間。

其終結直至最後被傳喚之被告人之答辯期之終結，明顯延長了。

17.4. 答辯狀之形式要件 (requisitos formais da contestação)

原則與第 389 條所規定之起訴狀之要件一樣。

但某些可以免除。事實上，因為法院已在起訴狀內指出了，當事人、訴訟的形式及利益值亦一樣。

按第 101 條第 2 款之規定，應用分條縷述之方式指出有關依據 (fundamentos)。
答辯狀之首部只需要是：

“對由 *António da Silva* 以通常程序而提起之訴，*Manuel Lopes* 作出答辯如下：……”。

17.5. 答辯狀之順序編排

應按下述順序分別指出：

延訴抗辯事由；

永久抗辯事由；

被告對由原告主張之事實提出爭執；

反訴（倘提出）（第 419 條）。

異議之模式 (modalidade da oposição)

在答辯狀內異議之模式非常多。

倘答辯是一種防禦方法，例外地亦可以是一種攻擊方法 (meio de ataque)。
例被告對原告提出一個反訴（第 218 條及第 419 條）。

第 419 條規定：在答辯狀內，應以分開方式提出反訴”。倘被告人提出反訴，反訴則成為被告人對原告人之反擊。這是防禦與攻擊，即一種交叉之訴。

第四百一十九條

反訴之提出

一、反訴應在答辯狀中明確標明及分開提出，並按第三百八十九條第一款 *c* 項及 *d* 項之規定，闡述有關依據以及在結尾部分提出有關請求。

二、反訴人尚應聲明反訴之利益值；如不聲明反訴之利益值，答辯狀仍獲接收，但須請反訴人指出有關利益值，否則反訴不予受理。

三、如反訴程序之進行取決於反訴之登記，或取決於反訴人作出之任何行為，而在所定期間內並無作出有關登記或行為，則駁回對被反訴人之起訴。

第 218 條指出了容許反訴之情況。

即使答辯無被告人作出反擊之一面，而是一般防禦，亦有各種不同之形式：

—— **直接防禦** (defesa directa) (**提出爭執**) (impugnação)；

—— **間接防禦** (defesa indirecta) (**抗辯**) (excepção)。

第 407 條第 2 款區分這種提出**爭執**及**抗辯**之情況。

“a.倘被告人對在訴狀內主張之事實提出爭執，或果，則為反駁防禦；倘

b.援引阻礙審理實體問題之事實，或作為原告人主張之權利之阻止、變更或消滅理由，決定請求完全或局部理由不成立”。

在**提出爭執**方面（**直接防禦**），被告人正面攻擊原告人之請求，反對原告人之主張。既可以反駁有關事實，亦可承認這些事實，但堅持這些事實不發生原告人所給予之後果。則既可否定有關事實，亦可否定理由及有關法律結論。

在**抗辯**方面（**間接防禦**），被告人主張阻礙原告人請求之事實（權利之消滅時效已到，已支付，免除等）或阻止法院審理之事實（無正當性、無能力……等）。

18. 間接防禦：抗辯事由

被告人以抗辯理由作為防禦，即主張任何事實，發生或已發生，或改變由原告人主張之實體權利，或阻止法院受理實體問題。

按照上文所述，有兩種抗辯事由：

—— 延訴抗辯；

—— 永久抗辯。

這種區分源自羅馬法，但今日各個訴訟法律體系間之區分形式有別。

第 412 條規定：

一、抗辯分為延訴抗辯及永久抗辯。

二、延訴抗辯妨礙法院審理案件之實體問題，並按情況導致起訴被駁回或將有關案件移送至另一法院。

三、永久抗辯導致請求被全部或部分駁回；該抗辯係指援引某些事實，妨礙、變更或消滅原告分條縷述之事實之法律效果。

18.1. 延訴抗辯（*excepção dilatória*）

如上所述，延訴抗辯引致駁回起訴或將案移送予另一個法院。

第一種現象見於無當事人能力、無訴訟能力、欠缺代理及所有其他延訴（一時）抗辯事由，相對無管轄權則除外。將案移送另一法院，只在法院相對無管轄權之情況才出現。

延訴抗辯列於第 413 條。這種載列只是例列（*enumeração exemplificativa*），基本上已十分完整。

18.2. 永久抗辯（*excepção peremptória*）

永久抗辯指理由成立時、則權利消滅、或權利會以利於被告人之方式轉變之抗辯。

有別於延訴抗辯，現行法律並無將永久抗辯列出來，即使在舊法中也只是列出（因條文使用：“除其他外”）：**既判案**（*caso julgado*）及**時效**（*prescrição*）（舊法典第 496 條）。

José Alberto dos Reis¹³教授指出：“除了時效及既判案外，還有其具實體法性質之永久抗辯，例因無能力或有瑕疵之同意而使合同無效、支付、免除、抵銷”¹⁴，“更新、混同”，“訴權除斥期已過¹⁵等”。

19. 直接防禦：提出爭執（impugnação）

第 407 條第 2 款規定：

二、被告作出防禦時：

a) 如反駁起訴狀中分條縷述之事實，或聲稱該等事實不可產生原告欲取得之法律效果，則屬透過提出爭執作出防禦；

b) 如陳述妨礙審理案件實體問題之事實，或陳述作為妨礙、變更或消滅原告所提出之權利之原因之事實，而該等事實導致全部或部分請求理由不成立者，則屬透過抗辯作出防禦。

應考慮第 410 條第 2 款之規定：

二、對於不提出爭執之事實，視為已承認之事實；但從所作之防禦整體加以考慮，該等事實係與其有抵觸者，又或該等事實屬不得自認或僅得以文書證明者，不在此限。

三、如被告聲明不知悉某事實是否屬實，而該事實為被告個人之事實或被告應知悉者，則該聲明等同於自認；反之，該聲明等同於提出爭執。

四、提出爭執之責任及上款之規定，不適用於由檢察院代理或由依職權指定之律師代理之無行為能力人、失蹤人、不能作出行為之人及不確定人。

容許以協定方式承認由原告人主張之事實，相等於自認這些事實。

20. 反訴（reconvenção）

反訴是指被告人在答辯時、針對原告人提出一個請求。

第 419 條第 1 款指出反訴應以分立方式提出，指出其依據及以請求（pedido）作結論（第 389 條第 1 款 c 及 d 項）。

反訴人還應指出反訴之訴額（利益值），倘無指明，並非不接受答辯，而是邀請反訴人指明訴額（利益值），否則將不考慮反訴請求（第 2 款）。

反訴以某特定要件為前提：

實體要件（列於第 218 條第 2 款 a、b 及 c 項）；

程序要件（載於第 218 條第 3 款及第 28 條內）。

實體要件（requisitos substantivos）

按照第 218 條之規定，反訴可以是：

倘被告人之請求乃源自作為起訴或防禦之依據之法律事實（第 218 條第 2

¹³ 見《民事訴訟法典評釋》第三卷，第 88 至 89 頁。

¹⁴ 訴訟上之補償是反訴之事宜：見第 274 條第 1 款 b 項。

¹⁵ 例：商法典，支票之訴權除斥期為 6 個月。

款 a 項)

例子：

在一宗意外裏兩人同時受有損害。A 針對 B 提起一損害賠償之訴，將責任歸責於 B。B 認為過錯在於 A，故向其作出反訴，要求損害賠償。被告人之請求乃源自原告人之請求之同一事實，此為作為原告人起訴之依據之事實。

A 針對 B 要求返還一所有權；B 辯稱該房地產屬他所有，並指 A 對該產業造成損害。B 可以反訴，請求有關賠償，因為請求了源自同一法律事實（作為防禦之依據之法律事實）。

倘被告人主張獲得司法補償或使修繕費或對物之費用享有實際權力，因而提出要求交付該物（第 218 條第 2 款 b 項）。

假設：A 訴 B，要求收取特定金額。然而 B 是 A 之債權人（一筆金錢之債），故在答辯時提出其反訴，目的是以此方法獲得**司法抵銷**（compensação judiciária）。

注意：只有**司法抵銷**方能載於反訴內。**法定抵銷**（compensação legal）乃屬**永久抗辯**之一種防禦方法，而非反訴（參閱民法典第 838 條及續後及民訴第 412 條第 3 款）。

倘被告人之請求是獲得原告人欲獲得之相同效果（第 218 條第 2 款 c 項）。

例如：A 訴 B，以法律所定之部分依據而提起爭訟離婚，而 B 亦有意離婚，但依據不同，對訴提出答辯及請求裁定原告理由不成立外，並以其主張之依據為基礎，在利於 B 之情況下判處離婚。

B 之請求是反訴中提出，故其目的是“為己利益獲得與原告同樣希望獲得之法律效果”。

程序要件

現在我們看看反訴之程序要件：

倘原告人之請求相等於有別於原告人請求之訴訟形式，則不接受反請求，除非不同形式及由不同之請求價值所致（第 218 條第 3 款）。

反訴所要求之另一個程序要件載於《民事訴訟法典》第 218 條第 3 款——則是《民事訴訟法典》第 28 條所定之要件。

一、審理訴訟之法院得審理透過反訴所提出之問題，只要其對該等問題具管轄權。

二、如因反訴不能在澳門法院提出，或有關反訴原應由仲裁庭審理，以致審理該訴訟之法院不具管轄權審理該反訴，則駁回對原告之反訴。

三、如因有別於上款所指之其他理由，以致審理該訴訟之法院不具管轄權審理反訴，則須將有關反訴之訴訟卷宗副本移送具管轄權之法院，而有關訴訟繼續在原法院進行。

按照第 218 條第 1 款任一項之規定而提出反訴後，應指出其依據，以請求作結論時要有請求（按第 389 條第 1 款 c 及 d 項之規定（第 419 條第 1 款））。

因為反訴在程序裏出現另一個訴，提出了另一個請求。為此可產生程序上之不同之後果。

反訴人必須指出反訴之訴訟利益值（第 419 條第 2 款）。由於第 250 條第 2 款之規定，由被告人提出之反訴請求利益值須再加上由原告人提出之請求之利益值。

如此，倘由原告人提出之請求利益值為 20,000.00 元（兩萬元）澳門元，倘被告人之請求利益值為 60,000.00 元（六萬元）澳門元，訴訟程序至提出反請求前仍採用簡易程序，隨後馬上改為按通常程序進行訴辯書狀階段原以答辯狀作為最後一份書狀（在第 672 條所定之情況下，極其量可有第三份訴辯書狀——對答辯之答覆），現還有原告之反駁（réplica）及被告之再答辯（tréplica do réu）。

自動改變訴訟形式，由簡易程序轉為通常程序。

這種因出現反訴而引致之程序改變，屬於異常程序。例如：被告人被傳喚以便在十五天內作出答辯（簡易程序），然而，自此之後，對於其後之訴辯書狀所適用之期間，將是通常程序內之期間。

21. 提交答辯及續後行為

作為答辯狀後，要將其交到法院辦事處。

自提交起計十天內，被告人必須繳交最初預付金（preparo inicial）（數額等於原告人已交之數額）。

倘被告人無繳付訴訟預付費用，則會被通知在十天期內在有關帳戶內存放，同時附加等額之司法費用（《法院訴訟費用制度》）。

假設答辯狀適時提交、亦繳付預付金，則可繼續另一份訴辯書狀：原告之反駁（réplica）。

22. 原告之反駁

22.1. 概述

將答辯之提出通知原告人（第 411 條第 1 款）。原告人可在其反駁內作出回覆。**原告之反駁**之作用是供原告對**抗辯事由**（excepções）作出回覆（倘有**抗辯事由**），以及對反訴提出**防禦**，但原告人不得對反訴再提出新之反訴（第 420 條第 1 款）。

22.2. 反駁之形式及提交之期限

原告之反駁須以訴辯書狀之方式作出（或稱：分條縷述方式製作）（第 101 條第 2 款）。可於十五天期內提出，自通知提交答辯狀。

倘提出了反訴，該期間則為三十天（第 420 條第 3 款）。

在下一條目我們將看看延長這個期間之理由。

22.3. 原告反駁之功能（funções da réplica）

我們可以將反駁之功能分類成為：

正常功能（funções normais）；

偶有或例外之功能（funções eventuais ou excepcionais）。

通常原告之反駁擔當兩種功能：

主要功能（função principal）：對被告之答辯作出答覆；

次要功能（função secundária）：解釋及充實起訴狀。

反駁之主要功能是對被告之答辯作出答覆。

反駁應對在答辯狀內所主張之事實作特定指明之反對，對無提出爭執之事實視為確認，一如**答辯狀**般——見第 410 條及第 424 條。

次要地，反駁供原告堅持其在起訴狀內所述之論據，尤其是在答辯狀內被批評之各項內容。

原告之反駁（réplica）亦擔當偶有或例外之功能，我們指出其中兩項：

按第 217 條第 1 及第 2 款之規定，在反駁狀內，原告人（即使無得到被告人之同意）可變更請求或訴因。反駁狀之作用往往是對訴之基本要素（elementos essenciais da causa）作出變更。

倘被告人曾提出**反訴**，反駁則作為對反訴之答辯（contestação do pedido reconvençional）。

為此，在這情況下，提交原告之反駁之期間為三十天。因為須確保被反訴人與提出“反訴”之被告有相同之防禦方法（第 403 條第 1 款及第 420 條第 1 款 b 項）。

23. 再答辯（tréplica）

此訴辯書狀之功能及提交期間見第 421 條（自通知原告之反駁起計十五天）。

基於第 424 條的規定，**再答辯**須對原告人在其**反辯**狀內提出之新事實作特定指明之反對，否則視為確認了有關事實。

24. 嗣後訴辯書狀（或稱為：嗣後訴辯書狀）

除了上文所述之各種訴辯書狀外，還有嗣後訴辯書狀——見載於第 425 及第 426 條。

不論原告或被告均可透過此等書狀提出在正常書狀階段終結後發生之創設、變更或消滅權利之事實，或這些事實在這些期間之前已發生，但提出一方事前並不知道。

嗣後訴辯書狀必須在事實發生後、或知悉這些事實後十五天期內提出（第 425 條第 3 款）。

法官可以拒絕該等書狀。倘接受，則須將提交這份書狀一事通知另一方當事人，後者可在十天內答覆，亦可至辯論結束前，甚至在已指定庭審期日之後作

出答覆，但需遵守第 426 條之規定。

25. 宣告之訴之訴訟關係之變更

訴訟關係恒定原則載於第 212 條，其中規定“傳喚被告後，訴訟程序在人、請求及訴因方面均應維持不變，但屬法律規定可改變之情況除外”。

從該規範之最後部分中可得知該原則並非一個絕對原則。訴訟法律關係可有變化。

訴訟法律關係之變更可以是：

主體變更——倘影響訴訟關係之主觀元素（法院及當事人）；

客體變更——倘影響訴訟之客觀元素（請求、訴因及訴訟形式）。

現在看看這些情況。

25.1. 主體變更（modificações subjectivas）

可以是關於：

法院；

當事人。

關於法院之變更，可以是：

法院本身；

在法院履行職務之人。

倘案之司法機關被撤銷或在事宜或等級方面變為無管轄權，在某些情況下，由某一法院處理之訴訟得轉移到另一個法院。民訴第 134 條第 3 款，第 28 條第 3 款及第 33 條第 1 款，以及十二月廿日之法律 9/99 號第 21 條。此條所述的內容為前述民訴法律條文之例外情況。

因在法院履行職務之人出現變更，例提出迴避之附隨事項、或要求法官聲請迴避（第 311 條至第 322 條）、或法院職員之迴避或聲請迴避（第 322 條至第 325 條），還有法官死亡或辭職之情況等。

影響當事人之主觀變更可於下述情況出現：

加入訴訟（Integração）（要求新之當事人作為主要參加人而參加訴訟），根據第 262 條。

在訴待決期間、因被告或原告死亡而出現代替當事人，後經由原告提出**確認資格之附隨事項**（incidente de habilitação）之情況（第 301 條及續後）。

按第 215 條及第 306 條規定藉生前行為將訴訟中之權利移轉而出現代替當事人之情況。

第三人參加（對訴訟關係而言之第三人），其形式有：自發主參加（第 262 至 266 條）、誘發主參加（第 267 至 271 條）、輔助參加（第 272 至 275 條）、輔助（第 276 至 282 條）、自發對立參加（第 283 至 287 條）、誘發對立參加（第 288

至 291 條)、透過第三人異議之對立參加(第 292 至 300 條)。

25.2.客體變更(modificações objectivas)

可以是關於：

1)-請求(pedido)

這些變更可以透過當事人間之協定(第 216 條)、或原告之單方意志而出現——(第 217 條)。

請求之變更可以是**請求在量**方面之變更(量之變更)、或甚至代替其**標的**(質之變更)。

2)-訴因(causa de pedir)

亦可透過當事人間之**協定**(第 216 條)或原告之**單方意志**而作出(第 217 條)。

3)-訴訟形式(forma de processo)

倘選擇形式錯誤、或出現法律定為改變**訴訟形式**之事實,則出現這種變更。

倘**訴訟形式**選擇錯誤,訴訟關係可在第 145 條及第 394 條第 3 款所定之限制內出現變更。

關於引致**訴訟形式**變更之事實,我們看看部分例子：

——倘被告提出一反訴,請求利益值超過 50,000.00(五萬)澳門幣,但原告人之請求利益值未達此額,程序由簡易程序轉成通常程序(第 371 條及第 250 條第 2 及 3 款)。

——倘被告人不答辯,且無第 406 條所述之抗辯情況,而被告人又缺席應訊,倘屬於具效力之缺席,則改變宣告之訴之通常程序之正常進程。

——倘被告自認有關事實,只在解決有關法律問題方面與原告人有分歧：在此情況下,無需更多的證據,一如第 429 條第 1 款 b 項所規定般,法官立即審理案件之實體問題。在此情況下,在訴訟形式上出現重要改變,因為獨任法官可在**清理批示**裏作出審判而令程序終結。

25.3. 概要

訴訟關係之變更

主體之變更(modificações subjectivas)

——**關於法院**：a)-關於法院本身；

b)-關於在法院履行職務之人；

2. ——**關於當事人**：

a)-加入訴訟(Integração)(第 262 條)；

b)-死因繼承及確認資格(第 301 條)；

c)-生前繼承(第 306 條)；

d)-第三人參加(第 262、272、276 及 283 條)。

客體變更(modificações objectivas)：

- 關於請求：質方面與量方面：
- a)-因當事人協定（第 216 條）；
 - b)-因原告之單方行為（第 217 條）；
2. ——關於訴因：
- a)-因當事人協定（第 216 條）；
 - b)-因原告人之單方行為（第 217 條）；
3. ——關於程序形式：
- a)-因錯誤選擇訴訟形式所致（第 145 條及第 394 條第 3 款）；
 - b)-因其他事實所致：第 250 條第 2 款（反訴）；第 405 條（不到庭）；第 429 條（清理批示）。

第三節

清理及準備階段（fase do saneamento e preparação do processo）

26. 概述

題述階段載於《民事訴訟法典》第 427 至第 432 條。

訴辯書狀階段完成後、則出現這個新階段，目的是使訴在可以審理實體問題之條件下繼續進行。

此為 1939 年葡萄牙民訴法典之一種創新之處，立法者認為在訴辯書狀階段完成後，先清除形式及無關重要之問題。但按 1939 年前之舊制度，這些問題只在終局判決時解決。

在學習**清理階段**時，我們將會按順序考慮兩個方面：

- a)-決定其內容（實體方面）；
- b)-在該階段內程序行為之順序（形式方面）。

27. 清理階段之實體內容

關於內容，清理通常分成四個不同之步驟：

- 1.-清理程序：審理程序問題——考慮各種前提及認定無效（427 條第 1 款 a 項）；
- 2.-正規化：指明確定性地視為既證之事實（430 條第 1 款 a 項）；
- 3.-簡縮或綜合：選擇對最後判決有（關鍵）作用，且在訴辯書狀中之事實及指出具爭議之事實（430 條第 1 款 b 項）；
- 4.-預備證據——由當事人指出準備提出之證據（431 條）。

在某些情況下，清理及準備階段除上述四方面外，或會體現在一個真正之提前審判：倘卷宗已包含解決爭議問題所需之全部材料，在此清理階段內法官可立即作出審判（第 429 條第 1 款 b 項及第 3 及第 4 款）。

28. 清理階段之形式內容

在形式上，可以分成四個不同之行為：

- 1.-清理前之批示（並不一定有）（427 條）；
- 2.-試行調解（428 條）；
- 3.-清理批示（429 條）；
- 4.-預備證據之行為（431 條）。

29. 試行調解

在時間上，是在提交訴辯書狀後嘗試進行調解。

然而，**此行為**只在第 428 條第 1 款最後部份所述之情況下才有，倘法官認為有需要，注意第 428 條第 1 款的規定“…得…試行調解…”以便：

- a-當事人和解（第 428 條第 3 款）；

b-可立即審理全部或部分主要請求或反訴。
我們細心地分析這兩種情況。

29.1. 當事人和解

一如第 235 條第 2 款規定：“當事人亦得於訴訟程序之任何時刻就案件之標的進行和解。”

而跟據 229 條 d 項，和解是訴訟程序消滅之原因之一。和解後，“法官僅須以判決認可…並按有關內容作出判處…”（242 條第 4 款）。

29.2. 立即審理案件之全部或部份實體問題

倘法官認為可審理請求而無需更多證據，則在此時可根據第 429 條第 1 款 b 項的規定，立即審理案件之實體問題。在此情況下作成之清理批示具有終局裁判之性質。

30. 清理批示（despacho saneador）

30.1. 何時應作出清理批示

清理批示在 429 及 430 條有規範。

何時作出？

視乎情況，批示應在訴辯書狀階段結束之日起計，或按 428 條規定試行調解後起計二十天內作出。

30.2. 清理批示之目的

第 429 條列出了**清理批示**之功能或目的。值得小心分析這條規範。

批示之目的是：

審理可引致駁回起訴之抗辯事由，甚至無效之情況，即使其效果並非撤銷整個程序亦然（429 條第 1 款 a 項）。

決定永久抗辯事由是否理由成立；

立即審理案件之實體問題，只要訴訟程序之狀況容許無需更多證據已可全部或部分審理所提出之一個或數個請求（b 項）。

這些目的可歸為：

審定訴訟前提；

審理實體問題；

解決或有之問題。

30.2.1. 審理訴訟前提

這個標的相當於第 429 條第 1 款 a 項所述之內容。體現在審定所有訴訟前提，故包括當事人能力、訴訟能力、正當性及無管轄權。

倘欠缺其中一個訴訟前提，法官駁回對被告人之起訴（第 230 條）。但須注

意第 6 條第 2 款的規定。

清理批示所具備的這個目的（審理訴訟前提）清楚指出了立法者之意圖：只有當判決有其存在之價值時，程序方繼續、直到有終局判決。

然注意：**前提之問題**可以不在清理批示內解決。例有關問題之認定取決於舉證。在此情況下，法官只在作出終局判決時正式審理**前提問題**（第 563 條第 1 款）。然第 429 條第 2、3 及 4 款只容許該情況在非常有限之情況下發生，無論如何，法官必須指出其不審理之理由，指出妨礙其在清理批示審理有關問題之原因。

這裏再次體現出立法者給予清理批示之清理功能。

30.2.2. 實體問題之審判（*julgamento de fundo*）

可在**清理批示**內審判實體問題。

只需符合第 429 條第 1 款 b 項則可。

一如該項規定所述，審判可以是局部或全部。

在此情況下，對於請求之審理是間接的，而非直接的。

倘**永久抗辯**在清理批示中被判定為理由成立，而或在**清理批示**內直接審理請求，則會形成**實體上裁判已確定的案件**（*caso julgado material*）。

然而，倘**清理批示**只針對程序事宜（前提及無效），則僅會形成**形式上之既判案件**（*caso julgado formal*），即僅在作出此裁判之程序內發生效果（第 429 條第 2 款）。

清理批示可結束或不結束案件。

倘駁回對被告人之起訴，則案件結束。

倘完全駁回對被告人之請求，案件亦因此終結。

當然有可能對該批示提起上訴。

如法官不將案件結束，則應在清理批示中，按 430 條的規定對事實事宜進行篩選。

31. 事實事宜之篩選

在清理批示，如訴訟須繼續進行，法官亦須在對解決案件有用之分條縷述事實中進行篩選，而篩選是按照法律問題之多個可能性解決方法而作出。此外亦須選擇（用自認，當事人間之協定或具書證）作為依據之事實（第 430 條第 1 款 a 項）。

因而，選擇**既證事實**。自認之事實屬其真實性獲被針對一方當事人同意之事實。當事人間之協定之事實為並無按第 410 條規定提出爭議之事實（已承認之事實）。

在事實事宜的篩選方面，法官亦須指出各點具爭議之事實，且該等事實是對案件之判決所必須者。因為必須提出證據，故構成「調查之基礎」（430 條 1 款 b 項）。

指出具爭議之事實這一行為，舊之法典稱之為制作待證事實列（一個通用

之術語)，是法官之一塊試金石。一份準確制定之**事實疑問列**保證法官準確捕捉問題之基本要素，以及正向著完滿地找尋解決方案之方向工作。只有必需之內容，但全部必需之內容，都應一一列入待證事實列內。

在待證事實列內應包括：

- a)-事實（當然排除法律問題）；
- b)-必須是載於訴辯書狀之事實；
- c)-有爭議之事實；
- d)-按法律之各種可行解決方法，對解決案件有用之事實，又稱為**恰當之事實**（factos pertinentes）。

在這些概念中，只有第一個會存在困難，故我們詳細看看。

31.1. 事實之各點，事實問題與法律問題之分別

在學理方面區分**事實問題**（在清理批示中被視為調查基礎之組成部分）與**法律問題**（後者無需證據，而是由法院依職權解決），是極困難之工作。一直以來，無論葡萄牙或其他國家的學者皆在討論這個問題¹⁶。

在此不深入探討這個問題，簡單地說：如需要引用一個法律之規定，方能知道某個概念時，則我們面對的是法律的問題，即使簡單的解釋一個法律詞語亦然。

如在調查每個個案之情節時，需通過調查現實生活所發生的情況，而該事實之存在或不存在，並不取決於對任何一條法律規範之解釋者，則我們面對的是事實問題。

32. 待證事實列之製作（elaboração do questionário）

調查基礎之系統編排不應機械式地按照在訴辯書狀所分條縷述之事實為標準，而是按照一個由法官決定之邏輯標準進行，將解決爭議之各點所需之事實分組。

正是對於列入**調查基礎**之事實進行舉證。但往往制定了該文件後，可附加新之**事實**。

此見於兩種情況：

- a)-有嗣後訴辯書狀（第 425 條第 6 款及第 426 條第 3 款）；
- b)-第 553 條第 2 款 f 項容許合議庭主席當認為對案件判決所必須者，得擴大調查基礎之範圍。

33. 聲明異議（reclamações）

對事實事宜進行篩選後，須將有關之副本送交各方當事人（第 206 條及第

¹⁶ 見於 91 年 3 月 31 日在澳門舉行之由 Antunes Varela 教授主講之「法律問題與事實問題之區分危機」。

最高法院（沒在里斯本）僅受理法律問題，不受理事實問題（見 12 月 23 日第 38/87 號法合《葡國司法法院組織法》）第 29 條及《民事訴訟法典》第 722 條。在澳門，高等法院受理法律及事實事宜，按 3 月 2 日第 17/92/M 號法令第 55 條第 1 款。

430 條第 2 款)。當事人得以未包括某些事實、納入某些事實或所作之篩選含糊不清為依據提出聲明異議(第 430 條第 2 款)。

需在十天期內提出聲明異議及有關複本，此為第 103 條所定之一般期間。倘其中一方提出聲明異議，辦事處通知另一方當事人、以便作出答覆，為此交予其一份複本。而亦應在十天期內作出答覆。

僅對法官就聲明異議作出裁判之批示、不得提起上訴，只可在對終局裁判提出上訴時，就該批示提出爭執(第 430 條第 3 款)。

34. 通知當事人進行舉證

第 431 及 432 條規定了在清理階段最後實施之行為是：**通知當事人在十五天內聲請採取證明措施。**

第四百三十一條

提出證據方法

一、如訴訟程序必須繼續進行，辦事處須將清理批示通知當事人，或無清理批示時，將篩選事實事宜之批示，又或將對聲明異議作出裁判之批示，通知當事人，以便其於十五日內，聲請採取證明措施，更改於訴辯書狀中所提出之與證據有關之聲請，或聲請將辯論及審判之聽證錄製成視聽資料。

二、如未有作出清理批示，亦未有篩選事實事宜，須由法官命令作出上款所指之通知。

三、第一款所指之期間屆滿，且考慮辯論及審判聽證前進行之調查措施可能需要之時間後，法官立即指定辯論及審判聽證之日期。

第四節

調查階段（fase de instrução）

I 證據與舉證責任（prova e ónus de prova）

35. 證據之概念

35.1. 調查階段，或稱舉證階段

調查階段是一個程序階段：自第 431 條所述之通知至辯論及審判聽證為止，其中主要是開展的是調查的行為，又稱為舉証行為。

所有這些概念皆圍繞證據之基本概念，我們現在看看證據之概念。

35.2. 證據之概念

何謂證據？

《民法典》第 334 條指出了一個證據之概念。按照這條法律規定，證據之目的是展示事實真相。

另一個證據之通用概念：向法官証明其存有疑問之事實之司法或訴訟行為。

正而言之，證據是對具有法律重要性之事實真相之展示。

稍後我們將有機會探討這個概念。

35.3. 規範證據之規則性質

在規範證據之規定中，應區分**實體證據法規範**與**形式證據法規範**。

規範那些是可採納之證據、證據方法及其證明力之規範是**實體證據法**之規範。訂定提出證據之模式、即在法庭舉證之形式之規範，屬於**形式證據法**之規範。

關於實體證據法規範之性質爭議很大。部分學者認為這些規範屬於實體法之規範。（此為葡萄牙司法見解之觀點。）

其他學者認為實體證據法屬於程序法之組成部分。

這種理解，受到 Manuel de Andrade 教授之支持；並以意大利學者 Ugo Rocco 主張為依據：“在訴訟純屬公法性質之概念裏，證據理論皆為程序法之理論，而提及證據之《民法典》規範亦為程序規範”¹⁷。

但另一部分學理認為證據法規範具有混合性質；當然並非因應這些規範所在之法規而定，而是因應所規範之證據事宜而定。

因此：

——規範在某個法律秩序所採納之證據方法之規定及訂定其證明力之規定屬於實體法規範；

——管制在法庭舉證模式之規範屬於程序法規範。

此為較合理之立場。

35.4. 證據之客體（Thema probandi）：事實

¹⁷ 見曾引述之 Rocco 之作品。

按照上文所述之證據概念，可知證據乃同事實有關。

事實上，法官依職權認定法律規範，不論當事人有否援引有關之法律規範。此為，羅馬人所述之：“汝給我事實，我給汝公正（Narra mihi factum, dabo tibi jus）（第 567 條第 1 部分）。

35.5. 那些事實須舉證及如何出現在程序內

在現行訴訟法內實行**處分原則**，而所規範者與舊法典有所不同。

實體法將群體意志反映在法律裏，而透過程序法規範之法院行為確保對該意志之尊重。

第 5 條裡規範了該原則的內容及範圍，並加入“在裁判時，法官須考慮之事實尚包括對所提出之請求或抗辯理由成立屬必需之事實。”（5 條 3 款）

即使法律不獲遵守，法院亦無需展開活動。法院之活動只按私人之意願才開始。

體現在法律上之群體意志（vontade colectiva），在私法方面，仍是一個受事實限制之意志：利害關係人之作為（actuação do interessado）。

不遵守法律則產生一個不合法行為（um ilícito）。但只在權利人要求下方可排除這個不合法行為。

但如何請求？

是透過行使訴權而作出請求，借助起訴而引發審判活動。

當提起一訴，原告並不可只請求法院之保護，還必須援引一事實狀況（situação jurídica），援引事實及提出一個主張。

當原告作出訴訟推動後，訴就在這個框架內進行。

這就是**處分原則**或**當事人主動原則**（一如 Manuel de Andrade 教授所稱般），其他學者（例如：José Alberto dos Reis 教授）稱為**處分性原則**（princípio da disponibilidade）而 Palma Carlos 教授稱為程序推動原則。而現行的《民事訴訟法典》第 3 條稱為當事人主動原則。

自然，就是對原告在訴訟提供，且為被告反駁之事實，需要提出證據。

通常證據所針對的就是該等事實（第 5 條第 2 款第 1 部分及第 567 條第 2 部分）。

一如 Goldschmidt 寫道：“**當事人之申明及所提供之證據是判決之唯一依據**”。

但這個規則有一些例外情況：

並非所有由當人主張之事實皆需證明：只有有用或恰當之事實（factos úteis ou pertinentes）才需證據（第 430 條第 1 款及第 433 條）。

除了當事人陳述之事實外，法院可以採用：

明顯之事實（factos notórios）——無需主張，亦無需證明，故並非所述規則之例外情況（第 434 條第 1 款）；

因履行職務而知悉之事實——無需主張、但法院需透過附具之文件而証實（第 434 條第 2 款）。

事實上，僅最後一項所述之事實才是通則之一個例外情況。

除第 5 條第 3 款所指之必需事實外，法院可依職權考慮在案件之調查及辯論中得悉之輔助事實。

36. 主張責任（*ônus da alegação*）與舉證責任（*ônus da prova*）

36.1. 概念

在上文已指出有關基本原則：誰主張權利，誰必須援引權利所建基之事實，只有援引證據方能證明事實。只有證明事實方能成功主張有關權利。方能主張權利，證明有關事實及說服法官。

證明事實之負擔稱為**舉證責任**——此為民法典第 335 至第 337 條之用語，但這個責任（負擔）以另一個責任為前提：**主張之負擔**（*ônus de alegar*）。

誰人主張權利，需證明產生要求司法保護之權利之事實，要證明這些事實，須先援引這些事實。

當事人負有**主張責任及證明之責任**。

主張責任先於舉證責任。

36.2. 處分原則與主張及證明之需要

很明顯，所述之取向（主張及證明事實之需要）乃因採用**處分原則**（或程序推動原則）所導致（在現在程序立法方面）。

在受這個原則影響之立法內，私人之活動限制了法官之權力，不單是活動之開始及所請求法律保護之幅度，而且在事實之取得方面亦一樣（上文所述之保留則除外）。

倘維持單純之調查制度（指法官可自由調查事實，在非訟事件之程序中（第 1207 條第 5 款）明顯具有這些特徵），情況則不同。

在**處分制度中**，當事人負有主張及證明事實之負擔，而這事宜法院必須審議。倘未能證明有關事實，而這些事實乃確定其權利之關鍵，法官則作出不利其之決定，此有別於羅馬法：倘無提供證明，法官則放棄審判。

36.3. 現代訴訟理論之取向減輕所述之原則之作用

不遵守舉證責任之原則會使請求不被接納之情況，今日受到很大之約制。

一直以來訴訟公開化及實行實質公正（而非形式公正）使法官之權力擴大，甚至強制法官負有調查責任。例子有：第 6、7 及 8 條第 1、2 及 4 款、第 106 條第 1 款及第 548 條。

這個向法官強施之義務有其理由所在，因為法官在訴訟方面有一個特殊任務（此為其職務之特點）：宣示一個主張是否與法律相符，如相符，則命令滿足有關請求。為此，應容許法官必需之調查以便作出裁決；以查明爭訟案中組成實

體決定之事實。

面對法官調查之義務，**舉證責任**之價值比之過去有所不如。

今日，**舉證責任**仍由當事人承擔（《民法典》第 335 條及第 336 條），且應考慮第 437 條關於**舉證責任**重要性之規定：“如就一事實之真相或舉證責任之歸屬有疑問，則以對因該事實而得利之當事人不利之方法解決。”。

主張一方當然須證明其主張之事實；然應僅主張對案件之裁判具法律重要性之事實。

無關重要之事實，不單不構成證據之客體，亦妨害訴訟之進行及其清晰性。

然而，澳門《民事訴訟法典》第 436 條規定：法院應考慮訴訟程序中取得之一切證據，即使該等證據非由負舉證責任之當事人提出，或非由其所聲請進行之措施中獲得，又或並非從該當事人所查得者亦然，但不影響因一事實非由特定之利害關係人陳述而聲明無須理會該陳述之規定。

37. 舉證責任之負擔

是指由雙方當事人（原告及被告）為訴訟提供解決爭議所需之事實證據時，而非指這個負擔由兩者中之任一方負責。因在法律上屬重要之事實之舉證責任由雙方當事人分擔，這種分擔是一個極重要及困難之問題，此為分擔**舉證責任**之問題。

由於這是分擔證明事實之問題，這個問題應以事實之分類為基礎。故將法律事實作出分類是十分重要的，這種分類澄清了在法庭分擔舉證責任之問題。

有多種事實分類之方法。

例可將事實分類成：

A

(1)

a) **主要事實**（factos principais）——是裁判之條件要素，是實體法之適用前提，故亦是訴訟標的之條件要素；

b) **輔助事實**（factos acessórios）——指與證明主要事實之證據方法之證明力有關之事實（例：證人之可信性）。

(2)

a) **具體事實**（factos concretos）——指有特殊個體性之事實；

b) **抽象事實**——指具有概括性質之事實。

(3)

a) **內部事實**——關於精神生活之事實（意思、思想及信念）；

b) **外部事實**——在外界反映出來之事實。

(4)

a) **直接關連之事實**（factos próximos）——與訴之標的有直接連繫之事實；

b) **非直接關連之事實**（factos remotos）——標的之關係十分間接之事實。

(5)

a)創設性事實；

b)妨礙性事實；

c)變更性事實；

d)消滅性事實。

其他分類：

A：

——創設性事實；

——變更性事實；

——消滅性事實；

B：

——主要事實（同規範或關係有關）；

——次要事實（同身分有關）；

——容許性事實（使主要事實發生效力）；

——阻礙性事實（其他）。

在這些分類之中，對程序及舉證責任十分重要的是第一種分類中之第 5 種事實及第二種分類的所有事實。

現在我們利用第一種分類方法去分析**舉證責任（負擔）**之問題。

現在我們考慮關於下述事實之**舉證責任**問題：

——創設性事實；

——妨礙性事實；

——變更性事實；

——消滅性事實。

對於這些在訴訟方面十分重要之事實，誰人負舉證責任？

我們嘗試回答這些問題。但需先考慮一些先決問題。

37.1. 舉證責任之性質

有舉證責任（*onus*）或舉證義務（*obrigação de provar*）？不舉證會引致真正之法律制裁？

按照一般見解，舉證責任指法律強制規定由一方或雙方爭訟人證明由其主張之事實。此為民法典第 335 及第 336 條之意思。

學者正是因此意思而使用這句術語。將處分原則適用於證據事實事宜正是要求各造當事人按法律標準證明由其主張之事實。

Ugo Rocco 稱：“舉證責任與證據之可處分性有關（*disponibilidade da prova*）。故屬於一種負擔（*encargo*）。

然不履行這些負擔，則引致其主張會被駁回，（倘所主張之事實是請求之理

由成立之條件)，有學者主張欠缺證據會對無證明所陳述之事實之一方當事人產生一個真正之制裁。

但可以指出：這種制裁並非法律性之制裁，而是一種經濟性制裁，但無論如何，這是一種不利之狀況（desvantagem）。

其他學者將**舉證負擔**與**舉證義務**區分。Zanzucchi¹⁸認為：倘法律強制規定某人要作出某特定行為，以滿足另一人之利益、同時犧牲自己之利益，則屬於一種**義務**（絕對義務）；倘法律規定某人為自己利益應為之行為，則屬於**負擔**。

在這個指引下，給予法官廣泛之調查權力（相對當事人行使處分原則而提出第 5 條 3 款之事實來說），法律規定所有人，即使與案件無關者均須為搜集證據提供合作。此為**合作原則**之體現分別反映在《民事訴訟法典》第 8 條及第 442 條內。

運用上述**義務**與**責任**之區分後，對於第三人來說，有人稱此為證明之義務。然而，倘舉證責任針對雙方當事人，則並不是一種**義務**，而是一般之**負擔**。當事人有兩種合法之態度（舉証或不舉証），可從中作出選擇，而且他亦應該作出選擇，若不舉証，則在訴訟內承受不利之後果（desvantagens）。

37.2. 在那類訴內會出現舉證責任？

在開始分析這個問題之前，需先澄清會在那類訴內會出現**舉證責任**之問題。此為宣告之訴之專屬問題嗎？

舉證責任並非宣告之訴之專屬，因為在**執行之訴**及**保全程序**內亦存在。

就**保全程序**內，對於所請求之措施，申請人須握要地證明具備所需之條件；在**执行程序**內，須證明有**執行名義**（titulo executivo）或提供補充性證明。

對部分學者來說，**執行名義**之功能正是提供債權之合法證據（prova legal do crédito）。

37.3. 客體負擔及主體負擔

繼續探索解決舉證責任問題之路徑，要搜集這個難題之資料，我們還需探討另一個先決內容，就是區分兩個不同之問題：

——誰人必須作出證明？

——必須證明些甚麼？

第一方面相當於主體負擔

我們可以強調，在這個事宜上有一個一般性原則：主張事實之人負有舉證責任。證據由事實主張人提出，倘不提出證據，則其請求會被駁回。

部分學者稱此為風險（risco）：倘無提供證據，事實主張人則承受證據不足或不具證據之風險。**訴訟**（程序）**風險**是一個同**負擔**有密切聯繫的一個概念。更甚者：此為舉證主體負擔之後果或反映¹⁹。

¹⁸ 見 Eanzucchi 著之《Diritto Processuale》，第一卷，第 324 頁。

¹⁹ 見註腳四所述之作品，第 272 頁。

除了這方面（主體負擔）外，亦需考慮另一方面：要使某個決定具有某個特定之內容，應證明哪些事實？換言之：誰主張，誰必須舉證（主體負擔）；但必須證明些甚麼？

在這個問題內包括一個舉證之客體負擔（*onus objetivo da prova*）之問題。

值得強調只需證明對解決在訴訟中指出之法律問題有用及恰當之事實（*factos úteis e pertinentes*）。

即使在這些有用及恰當事實之中，部分事實可以免除舉證之行為。例如：

明顯事實（*factos notórios*）無需證明（亦無需主張）——第 434 條第 1 款。

理應舉證所主張之事實、但因事實所針對之對方無提出爭執而視為已獲承認之事實（第 410 條及第 424 條）。

作出自認之事實（第 477 條及續後）、或屬於法院依職權審理而獲證明之事實（第 434 條第 2 款）。

37.4. 訴訟取證原則及其在舉證責任方面之反映

在分析關於分擔舉證責任之前，我們還需考慮最後一個問題：關於違反舉證責任之一般性原則。

我們看看這個問題所指之內容。

雖然**舉證責任**由事實主張人承擔，法律希望法官在其能力範圍內保證事實真相。

為此確立了**訴訟取證原則**（*princípio aquisitivo da prova*）（第 436 條），依此原則，法院應考慮提出之所有證據，不論是否由當事人提出，但不妨礙法律規定某些對非為當事人主張，則視為不重要之事實。

從此原則中可得出一個重要之後果：倘當事人主張某個事實（故應證明這個事實），但無證明該事實，相反由另一方提出證據，法院則依後者所提之證據作出決定。在此情況下，不履行舉證責任，並無例外地使當事人處於不利後果之風險情況下。

申言之：規範舉證責任之一般原則、因法官權力之擴大而出現變更。

37.5. 舉證責任之分擔。各種學說

現在我們正式開始分析**舉證責任**之主要問題：爭訟人之間如何分擔這個**舉證責任**？

驟眼觀之，所述之一般性原則似乎（誰主張事實誰舉證）已經足夠。

然而，事實並非如此，Chiovenda 作出如此忠告：“由於很難全面及完整地表述舉證責任之一般性原則，亦很難提供一個絕對及理性之解釋理由”²⁰。為此，著者有意指出一個指引性標準之學理。

現在我們分析各種建議方案。

傳統解決方案

²⁰ 見由 Chiovenda 著之《Instituciones de Derecho Procesal Civil》，第三卷，第 98 頁。

受羅馬法啟發，**舉證責任**由申明事實之人承擔，以證明事實存在，而非否定存在事實之人承擔。(Negativa non non sunt probanda. Affirmanti non neganti incumbit probatio)

證據之利益說

按此見解，應先決定證據會對那一人有利，則由該人負**舉證責任**。

聲明事實之利益說

由 Carnelutti 提出之學理，他主張，對申明事實有利益之一方負**舉證責任**。

申明事實之責任說 (Betti)

有別於 Carnelutti 所述，Betti 認為**舉證責任**不應由對申明事實有利益之一方負責，而是純由申明事實之一方負責。因此以“申明事實責任”代替“利益責任”。

構成有利規範之前提之事實

Rosenberg 與 Guasp 為這個學理始創人，認為應先決定法律規範對誰人有利，而待證事實則是一個前提（法律規範假設部分之一個元素）。正是由此人負**舉證責任**。

因應欲得之法律效果、當事人所持之立場說

這是由 Micheli 所主張之理論，我們認同之理論，由爭訟人分擔**舉證責任**，應考慮下述元素：

- 當事人在訴訟內之立場；
- 主張事實之人欲獲得之法律效果之性質。

37.6. 所採納之學說之適用（最後所述之學說）

現在我們將最後所述之學說適用在上文所述之各類待證事實中：**創設性事實、妨礙性事實、消滅性事實及變更性事實**。

創設性事實之舉證責任

對創設性事實原告人負**舉證責任**。此為閱讀（民法典第 335 條第 1 款（？）及第 336 條第 1 款（？））所得之結論。

倘原告人無證明這些事實，被告人無需證明任何東西。

這個解決方案有其理由所在。事實上，創設性事實是指產生法律關係之事實，而原告人正主張他身為這種法律關係之積極主體之身分。由於在法庭所主張之權利以創設性事實成立為基礎，自然地由主張人負**舉證責任**。

妨礙性事實之舉證責任

妨礙性事實是指阻止原告人在創設性事實中欲得之效果之事實。

按照上文所述之規範，由被告人負**舉證責任**，不論有否提出直接防禦，或用抗辯方法作出間接防禦。

消滅事實之舉證責任

對原告人權利之**消滅性事實**之證明、由被告人負**舉證責任**，此十分自然：倘這些事實不成立（**消滅性事實**），對於原告人之權利、其存在屬於肯定，因來

自由原告人證明之**創設性事實**。

變更性事實之舉證責任

對於變更爭議法律關係之事實（故變更原告人之權利）、稱為**變更性事實**。

這些**變更性事實**常體現在**創設性**、**妨礙性**或**消滅性事實**方面（因應變更之意思），因應在每個具體情況下所具備之性質而定²¹。

38. 反證責任（ókus da contra-prova）

反證指主張及證明一個事實，而此事實是用來推翻另一個已陳述及證明之事實。

反證之問題有別於證明消滅性事實之問題：倘由被告人證明之消滅性事實，被原告人用另一個事實提出反對，則出現**反證**之問題。

反證之責任由誰人負擔？

主張推翻另一個已主張及證明之事實之人負反證責任。

須注意：反證以已有“證據”為前提。倘將被推翻之事實（妨礙性、變更性或消滅性事實）無被證明，則無反證之問題存在，故無需談及舉證責任（ókus）。

39. 消極事實之證明（prova do facto negativo）

“消極並非證據”之古老原則，今日已無效用。

古時，對消極事實之證明，存有很大困難。過往有人認為，幾乎必定可以證明某個事情已發生，因為曾留下充足痕跡。但要證明那個事實沒有發生……似乎不可能，或最低限度極為困難。例如，相比較之下較易的是證明某人已婚，但很難證身該人並非已婚。

故稱**消極事實**之證據為“極難之證據”（prova diabólica）。

今日，關於消極事實之證據，在許多情況下皆由法律強制規定。例如：以不履行債務為依據而提出賠償之訴。原告人要提出積極或消極事實之證據，此皆為其權利之創設性事實。在此情況下，需證明一個消極事實（明顯地給付之內容為一個事實，而非一種不作為）：必須證明債務人無履行其債務。

40. 舉證責任之約定倒置

爭訟人之間可否透過協定變更**舉證責任**之分擔？

學理之見解在這方面並不一致。

部分學者否定具備這種內容之協定之有效性。

José Alberto dos Reis 教授主張這種理解，他指出：“證據協定之有效性與法定制度相違背²²”。

考慮到訴訟之公法性質，我們認同 José Alberto dos Reis 教授之立場。

²¹ 見 Manuel de Andrade 教授所著的 “Noções...”, 第二卷，第 189 頁。

²² 見註腳四所述之作品，第 251 頁。

41. 調查階段。規範該階段之原則

按第 431 條之規定而向當事人作出通知及忠告後，當事人應提交哪些證據材料？

每一方當事人對於負舉證責任之事實、應提出有關證據。這是對第 431 條之解釋。

舉證乃在調查期間作出，乃指**清理階段**之後接著之階段。

我們知道**調查階段**可以是程序正常進行之一個時間順序狀態，或純邏輯順序，在多個階段內存在而組成之一套舉證行為。

作為時間順序狀態之**調查階段**，並不包括所有證明之行為。這點我們已知道。某些證據方法（例勘驗（inspeção judicial））只可在這個階段中提出，而其他證據方法，例如書證，可在**訴辯書狀階段**或**辯論階段**提出。

現在我們看看指引**調查階段**之各個主導原則。事實上，此為在訴訟之各個階段內、各種舉證活動應遵守之原則，而非僅於時間順序之**調查階段**。

調查舉證所遵從之原則有下述五個：

- 訴訟取證原則（princípio da aquisição processual）；
- 證據自由評價原則（princípio da livre apreciação das provas）；
- 辯論原則（princípio do contraditório）；
- 合作原則（princípio da cooperação）；
- 適時原則（princípio da oportunidade）。

現在我們扼要地分析每個原則。

41.1. 訴訟取證原則（princípio da aquisição processual）

此原則載於第 436 條內，Manuel de Andrade 教授形容為：其中一方當事人提出(確認及證據)之材料視為為訴訟而提供。即使利於他方當事人亦需考慮這些材料²³。

此原則直接適用在於利用一個事實之證據，即使由無舉證責任之一方提出亦然。

41.2. 證據自由評價原則（princípio da livre apreciação das provas）

“按此原則，一個事實之證明靠法官之心證，按照為訴訟而提出之證據材料（以及當事人在訴訟中之行為），同時參照其生活經驗及知識而產生這個心證，並非單純遵守法定之形式。而所裁判的是實質真相，而非形式真相”。

證據自由心證載於第 558 條第 1 款。但受該條第 2 款的約束。

41.3. 辯論原則（princípio do contraditório）

此並非證據或調查之專有原則，而只是在這方面較為重要之一個原則，即受證據損害之當事人應知悉所有對其不利之證據，以便可以作出監察及提出其或

²³ 與註腳三十四同，第 369 頁。

有之反對理由。

辯論原則載於《民事訴訟法典》多條規定內，如第 3 條第 1 款，就有關於**傳喚**的規定，第 51 條關於依職權代理不確定之人。

在證據方面，這個原則載於第 438 條第 1 款內：“如未進行證據所針對之當事人之辯論聽證，則不得接納及調查有關證據，但另有規定者除外。”

該條文第一部分為關於下述之情況：倘另一方可知道即將發生何事，原告人之利益受到威脅，且申請措施之實行可能變成無用（例**保全措施**之某些情況）。

在此情況下，法律規定了**辯論原則**之例外情況，這些例外情況有兩類：

禁止聽取對方（反方）：例占有之臨時性返還（restituição provisória da posse）（第 339 條）及假扣押（第 353 條第 1 款）；

容許法官因應適宜性而決定聽取或不聽取另一方當事人，例在**普通保全程序**內（第 326 條及隨後數條），**新工程之禁制**（第 356 條及隨後數條），制作財產清單（第 362 條及隨後數條）

41.4. 合作原則（princípio da cooperação）

指所有人負有協助發現事實真相之法定義務，並為良好司法作出貢獻之義務，無論是當事人或第三人亦然。

這個原則明示地載於《民事訴訟法典》第 442 條內；但亦反映在其他內容上，例如在訴訟方面國與國之間之國際合作，懲罰惡意訴訟（litigância da má fé）等。

41.5. 適時原則（princípio da oportunidade）

指在適當時間搜集證據，以便獲得預期之效果。

除了上述各項原則外（訴訟取證原則、證據評價原則、辯論原則、合作原則及適時原則），在調查方面還有其他原則，例口頭原則（第 440 條規）、集中審理原則（第 439 條）以及證據合規範原則（第 435 條）。

II

證據方法 (meios de prova)

第一分節

書證 (prova por documentos)

42. 文書之概念及其種類

42.1. 文書之概念 (conceito de documento)

現在我們看看書證——載於《民事訴訟法典》第 450 條及續後。

按《民法典》第 355 條之規定：“書證係源自文件之證據；文件係指任何由人編制用以再現或顯示人、物或事實之物件。”

對於證據法，文書（不論這個詞之廣義有多大，例在法學史方面之涵義）是指：“包含一個聲明之書面文件”，所有宣示性之書面文件，不論是意志之宣示 (declaração de vontade) 或認知之宣示 (declaração de conhecimento)，不論有否作為證據之目的亦然²⁴。

因此文書是指任何書面文件，包括用作證明一個或多個事實之宣示（意志或認知之宣示）。

42.2. 文書之法定分類

按照《民法典》第 356 條所定之法定分類，我們可以將文書區分為：

公文書 (documentos autênticos)：指由公共當局或公證員或另外一個公職員作成之文書（《民法典》第 356 條第 2 款）。

公文書可以是官式文書或非官式文書。

私文書 (documentos particulares)：指由任何一個人作成及簽署之文書，但並無公務員之介入。（《民法典》第 356 條第 2 款末段。）

經認證之文書 (documentos autenticados)：指按照公證法律之規定、在公證員面前，由當事人確認之私文書（第 356 條第 3 款）。

43. 公文書之類別，其證明力及可有之瑕疵

43.1. 公文書之概念

指出了文書類別後，現在我們看看公文書：指由公共官員作成，或經這些官員之介入，按法律之程序，在權限內及活動範圍內作成之文書。

43.2. 公文書之類型

可將公文書分成官式文書及非官式文書：

官式文書指：如公共當局、官員就文書所涉及之事宜及在地域上均具有權限繕立有關文書，且非處於法定迴避之情況而不得繕立文書，則其所繕立之文書

²⁴ 見由 Antunes Varela 所述之《民事訴訟法用書》，第二版，第 505/506 頁。

為官式文書。

非官式文書指：如公證員就文書所涉及之事宜及在地域上均具有權限繕立有關文書，且非處於法定迴避之情況而不得繕立文書，則其所繕立之文書為非官式文書（包括有證明書、證明及其他由其發出之同類文件）。

43.3. 公文書之證明力

《民法典》第 365 條第 1 款指出：公文書：（公文書對由當局或有關負責公證官員所作出之事實，及發出證明文件之實體以感知為依據而在文書內所證明之事實有完全證明力；發出文書者之個人意見僅作為裁判者自由判斷之要素）。

對於不構成當局或公務員作為之事實或超出其認知之範圍，可適法地指出不非事實性之方法，不論有否主張文書之偽造性。

43.4. 公文書之瑕疵

倘公文書為偽造則失去其完全證明力。

偽造（《民法典》第 366 條）可以是：物質或外部偽造；及內部之偽造。

前者指在文件之偽造；而後者是指文件內所載之人或事實之虛假²⁵。

43.5. 在澳門以外發出之文書之合法化

《民法典》第 358 條第 1 款容許：“由澳門以外之地方按照當地法律發出之公文書或私文書，與在澳門繕立之同類性質文書具有同等之證明力”。

第 358 條第 2 款規定：“然而，如法院有充分理由懷疑文書或其認定之真確性，則由法院自由判斷該文書之證明力，但另有規定者除外”。

44. 私文書之類型

可將私文書分類成：

- a．經認證之文書；
- b．經一般合法化之文書；
- c．一般私文書。

經認證之文書是指：“當事人按公證法之規定在公證員面前確認之文書，為經認證之文書”（《民法典》第 356 條第 3 款）亦即通過認證經確認之文書。

經合法化之文書是指：經承認，但並非在公證員面前確認之文書。

一般私文書是指由人書寫及簽署之文書，或僅由當事人之書面或由其簽署，但無任何公務員介入者。

44.1. 私文書之證明力

經公證認定作成人之私文書，對其作成人所作之意思表示有完全證明力，但不影響對文書虛假之爭辯及證明《民法典》第 356 條。關於合法化之文件，雖

²⁵參考民法典第 359 條 “文書欠缺法律所要求之某一要件時，由法院自由判斷其證明力。”

然法律無作出規定，可以接受的意見是文件屬於真實。

一般私文書，一般接受由某人作成，只要該人明示或默示承認（而不反駁）則可。

45. 書證之提出

可用下述四種之任一種方式提出書證：

當事人自發性提出（*oferecimento espontâneo da parte*）；

應另一方當事人申請；

法院主動要求；

由證人或鑑定人（輔助人）提交。

45.1. 由當事人自發性提出（*oferecimento espontâneo da parte*）

在提交文書之方式上，應區分：

關於分條縷述之事實之文書：通常應連同當事人主張之事實之訴辯書狀一併提交（《民事訴訟法典》第 450 條第 1 款）。

關於嗣後事實之文書：作證明提交訴辯書狀階段完成後、才發生之事實之文書，或因後來發生之事實而需提交之文書，可於程序之任何階段提出（《民事訴訟法典》第 451 條）。

45.2. 由另一方（反方）當事人申請

第 455 條容許任一方當事人可以要求擁有文件之另一方當事人交出文件。倘如此申請，則通知當事人提交文件。倘不提交或不作出合理解釋，對於證據效力而言，法院自由地衡量這種行為（第 456 條）。

然而，被通知之當事人可證明他無該文件（第 457 條第 1 款）。

第 458 條規定，訴訟案以外之第三人可以被通知提交其擁有其文書。

45.3. 法院主動要求（*iniciativa do tribunal*）

第 462 條亦規定法院可主動徵用文書、亦可拒絕將不恰當之文件附入卷宗內。

45.4. （*Junção pelas testemunhas e peritos*）

根據第 539 條作證言之制度的第 5 款的規定 “ “適用第 485 條第 3 款：“陳述者不得帶備書面陳述，但得翻閱文件或記錄日期或事實之筆記，以回答有關問題。” 的規定。”

46. 文書之歸屬（*destino dos documentos*）

第 467 條及隨後數條規定，文書須附入卷宗內，且通常在主案有確定判決之前不能取出。

我們指“通常”（*em regra*），因為可例外地將文件歸還予所屬之人，即使在

案件完結之前，只要指出有立即歸還之需要則可。

在後述情況下則，在案卷內須留有整份文書之副本，而獲交還之人在被要求時，必須出示正本（第 467 條第 3 款）。

除了這種例外之提前歸還外，通則是在裁判轉為確定後才歸還；返還文書可以是**強制性或任意性**。

不論有否申請書，返還屬第三人之文書（第 467 條第 4 款）及附入卷宗內之具有機密性之文書，屬於**強制性**歸還。

倘交還文書取決於當事人提出之申請，指交還附入卷宗之文書，則屬於**任意性**，並非**強制性**交還。

47. 考慮文書之條件 (condições de atendibilidade dos documentos)

要作為證據，文書須具備下述條件：

可閱讀——倘字體難以閱讀，則當事人必須提交一份字體清晰之副本，倘當事人不遵守，則被科罰款，而副本之成本由其負責（第 466 條第 1 及第 2 款）。

法院可理解之文書——倘文書用非澳門正式語文，且無稱當之譯本，法官可以要求當事人提供譯本（第 90 條）。

核實其真實性——按第 469 條的規定。

48. 對文書提出爭執 (impugnação de documentos)

倘連同最後一份訴辯書狀提交文件、或於後來提交文件（書證），須通知另一方當事人（第 453 條）。

倘提交文件乃因法官主動要求，則須通知雙方當事人。

將提交文件通知反方後，他可以採取下列態度：

——認同將文件附入卷宗及該文書的內容；

——就文書之真實性或準確性提出爭執。

須強調的是在第一種情況下，對私文書之字體及簽字視為屬實。

當事人同樣可以就文件本身提出爭執。

必須區分兩種情況：

——**公文書及經認證之文書**；

——**私文書**。

可透過**虛假** (falsidade) 為依據而推翻**公文書**之證明力——虛假附隨事項 (incidente de falsidade)，載於《民事訴訟法典》第 471 條第 1 款以及《民法典》第 366 條。

倘就私文書提出爭執，當事人可採取下述三種之其中一種立場：

或**主張虛假性**：

或僅反駁字跡及簽字之真實性，又或機械複製之準確性提出爭執；

或聲明不承認上述兩項具有真實性。

在第一種情況下，由爭執人證明文件之虛假性。

在第二及第三種情況下，由他方（當事人提交文件之一方）通過檢驗、或其他證明方法證明該文件之真實性。

在任何情況下，如提交文件時當事人在場，應在自提交文件十日內提出爭執，否則自通知附入卷宗時起十日內提出(第 469 條第 1 款結尾部份)

第二分節 當事人陳述之證據 (prova por confissão das partes)

49. 自認之概念

《民法典》第 345 條規定：自認係指當事人對不利於己、但有利於他方當事人之事實承認其真實性。

50. 自認之方式

50.1. 自認方式之概述

自認可以是（《民法典》第 348 條）：

訴訟上之自認 (confissão judicial)——“指在不論有否管轄權之法庭、或甚至在仲裁庭上所作出之自認，即使所涉及者屬非訟事件之程序亦然”。留在待決訴訟內作出（第 348 條第 2 款使用“在法庭”這個字眼）。

非訴訟上之自認 (confissão extra-judicial)——“凡透過與訴訟上自認不同之其他方式作出之自認，均為訴訟外自認”。在訴訟以外作出之自認（某種程序有別於司法自認）（第 348 條第 4 款）。

50.2. 非訴訟上之自認 (confissão extra-judicial)

非訴訟上之自認可以是：

書面（在訴訟程序內以文書方式證明）；

口頭（在訴訟程序內以證人證明）；

書面方式還可以是：

——**公文書**（用公文書或經認證文書證明）；

——**私文書**（用私文書證明）。

50.3. 司法自認 (confissão judicial)

關於訴訟上之**自認**，區分成為：

——**自發性** (espontânea)；

——**誘發性** (provocada)。

當出自當事人之主動、聲稱由反方主張之事實屬實，則為**自發性自認**（第 349 條第 1 款）。

倘要求當事人之口供，則屬於**誘發性自認**（《民事訴訟法典》第 477 條第 2 款）。

自發性自認可以：

在訴辯書狀內作出；

在程序內用書錄 (termos) 作出；

以獨立口供或聲明作出；

在審判聽證時、由具有特別權力之律師作出。

誘發性自認是指透過申請書而要求當事人作出之陳述而作之**自認**——一如《民事訴訟法典》第 477 條第 2 款所規定般。

不應將**當事人之陳述**（depoimento）與**自認**（confissão）混淆。倘陳述人之陳述引致承認由申請人（requerente）主張之事實，當事人之陳述方產生**自認**。

希望產生自認之人，應申請反方當事人或共同當事人作陳述（《民事訴訟法典》第 478 條第 3 款）。

倘作供人否定有關事實或作出一個不能產生自認之態度，則只存在一個當事人之陳述（depoimento de parte），並無**自認**。

然而，倘用這種方式獲得**自認**，《民法典》第 351 條第 1 款規定：對自認人產生完全證明力，除非法律視為自認不足，情況則不同，例倘自認是針對法律禁止承認或調查之事實，倘又或針對不能處分之權利，或自認之權利為不可能或明顯不存在（《民法典》第 347 條）。

50.4. 自認之證明價值（valor probatório da confissão）

關於自認之證明價值，必須區分：

訴訟上之書面自認、通常對自認人產生**完全證明力**，《民法典》第 347 條所定之情況則例外。

關於非訴訟上之自認，《民法典》第 351 條規定：其證明價值取決於作出自認之形式。

倘為**口頭自認**，則適用關於證人證供之規則；倘為**書面形式**，則適用關於書證之規則。

50.5. 自認之可撤回性

由於**訴訟取證原則**之適用，《民事訴訟法典》第 489 條第 1 款規定“不得撤回自認”。

然而，對於在訴辯書狀內之事實所作明示自認，可以撤回，只要另一造當事人無特定地接受則可（《民事訴訟法典》第 489 條第 2 款）。

50.6. 自認之無效或撤銷

自認可按一般的規定宣告因欠缺自認的意志或意志表達方面有瑕疵而被宣告無效或撤銷（正如《民法典》第 352 條第一款的規定）。然而宣告自認無效或撤銷自認之訴不妨礙出現自認情況之案件繼續進行（《民事訴訟法典》第 488 條）。

51. 當事人陳述（depoimento de parte）

如由任一當事人聲請作陳述，則其須立即逐一指出必須陳述之事實。（《民事訴訟法典》第 477 條第 2 款）。

一如所有其他證據般，必須在通知當事人舉證（第 431 條第 1 款）後十五天內提出申請。應指出當事人必須作出表示之事實，而這些事實必須是載於**事實**

疑問列內之事實。

只可要求有訴訟能力及無行為能力人之代理人、法人或公司之代理人作陳述（第 478 條第 1 及 2 款）。

自然地，無行為能力人之陳述只在其能力範圍內自認方具有價值（第 478 條第 2 款）。

同一條文之第 3 款將申請口供之可能性範圍擴大，規定：“每一當事人除可聲請他方當事人作陳述，亦可聲請本身之共同當事人之陳述”。

綜合言之，可申請下述人士之陳述：

有完全行為能力之當事人（他方當事人）；

共同當事人；

無行為能力人、法人或公司之代理人。

關於陳述所針對之事實，當事人之陳述受有三之面之限制：

其中一個我們在上文已指出：陳述只可針對作為調查基礎內之事實；

另一個限制：

1. 陳述之內容僅可為陳述者個人之事實或其應知悉之事實；

2. 然而，陳述內容不得包括當事人被指稱作出之犯罪事實或卑劣行為（《民事訴訟法典》第 479 條第 1 及第 2 款）。

最後，不接受就關於不可處分權利之事實作陳述（《民法典》第 347 條 b 項）。

52. 如何及在何處作陳述

通則是在辯論及審判時作陳述，有緊急情況，或作供人居住在另一個法區或不能到庭（《民事訴訟法典》第 481 條第 1 款）則除外。

倘當事人被親身通知作陳述，因患病而未能於指定期日及時間到庭，法官可命令其信任之醫生所陳述之理由是否屬實（《民事訴訟法典》第 482 條第 1 款）。

在作陳述時必須遵守法律所定之順序：

被告先作陳述，接著由原告作陳述（第 483 條第 1 款）。這種規定之理由在於：倘被告承認原告主張之事實，則原告之陳述在很多情況下並無作用。

在陳述時須遵守一定之步驟，其形式載於第 484 條至第 487 條：

這個形式包括：

第一個步驟：警告開始作陳述前，法院須使陳述者知悉其然進行之宣誓在道德上之重要性，以及使其知悉負有據實陳明之義務，並警告陳述者作虛假聲明時將受之處分（第 484 條第 1 款）。

第二個步驟：宣誓——接著，合議庭主席要求作供人宣誓：“以本人謹以名譽宣誓，所言全部屬實，並無虛言”。

拒絕宣誓相當於拒絕作陳述（第 484 條第 3 款）。

第三個步驟：初步訊問——由全議庭主席訊問作陳述之人，以認別其身分資料（第 485 條第 1 款第 1 部分）。

第四個步驟：詢問——之後，法官就每一個事實認別陳述者（第 485 條第 1

款第 2 部分)。

作供人必須準確及清晰地回答向其提出之問題，另一方當事人可申請為澄清或對答案作出補充所需之措施（第 485 條第 2 款）。

陳述以口頭方式進行（第 485 條第 2 款及第 440 條）。不論是否以書面記錄，可申請制作成視聽資料（第 448 條）。

按第 485 及 486 條之規定，訊問必須由法官作出；律師只可是為了澄清而請求陳述者加以解釋（第 486 條第 1 款），且可就法院向陳述者提問之某個問題提出反對（第 486 條第 2 款）。

第三分節 鑑定證據（prova pericial）

53. 概念

是由鑑定人（即對爭訟之事宜具有專門知識之人）所提供的意見，並將之帶到訴訟程序中作為證據的方法。

該證據方法在民訴第 490 條及隨後數條，以及民法典第 382 及 383 條中加以規定。而根據 382 條之規定，鑑定證據之目的，係在有必要運用專門之技術、科學或技能之知識下、或在基於涉及人身之事實不應成為司法勘驗對象之情況下，透過鑑定人而對事實作出了解或認定。

此證據方法與舊法典中所規定者有很多之分別舊法典。

第 568 條第 1 款規定：“鑑定證據可透過鑑定（arbitramento）進行——是指查驗（exame），檢查（vistoria）及評估（avaliação）”。在此三種形式上，可以區分為：a)關於目的，b)關於客體。

關於目的：

查驗（exames）及檢查（vistorias）——目的調查曾留下痕跡或可進行檢驗（inspecção）或可視覺性查驗視察之事實（舊法典第 568 條第 2 款）。

評估（avaliação）——目的是決定財產或權利之價值（舊法典第 568 條第 3 款）。

（2）關於標的：

查驗（exame）——針對動產或人；

檢查（vistorias）——關於不動產；

評估（avaliações）——可以針對動產或不動產（但只限於決定其價值）。

這些不同之處在新的法典中已不復存在。

53.1 由誰作出鑑定

根據《民事訴訟法典》第 490 條中各款的規定，鑑定係在有權限之公共機構或部門進行（例如：在澳門，在司法警察局的司法鑑定化驗室），如此為不可能，則法官須在對案件的事宜具專門知識之合適人士中指定一名鑑定人（第 490 條第 1 款）。

須聽取當事人的意見是否同意有關的指定。

按照第 3 款的規定，鑑於事宜特別複雜，在 e 項及 b 項所規定的情況下由不多於由 3 名之鑑定人進行鑑定。

在 491 至 500 條具有各項關於指定鑑定人所必須遵守的規定，該些規定屬於訴訟輔助人部分之組成部分。因此，受 491 條現規範的義務，以及經必要配合後，受關於法官之迴避及聲請迴避之現行制度（第 492 條 1 款）所約束。

鑑定

是鑑定人的工作，且須按《民事訴訟法典》第 501 條及隨後數條所述的手

續進行。

指定有關措施開始的時間及地點（第 501 條）；鑑定人須透過宣誓承諾認真履行獲委派的工作，除非鑑定人為公務員且在執行其職務下參與工作則無須宣誓（第 502 條第 1 款）；法官如認為有需要，得於檢驗時在場（第 503 條第 2 款）。

“鑑定人得借助一切為妥善履行職務而必需之方法，包括請求採取措施或作出解釋，或請求獲提供卷宗所載之何資料。”（第 504 條第 1 款）。

第二次鑑定（arbitramento）

鑑定可進行第二次。第二款鑑定的作用是按照第 510 條第 3 款的規定，對第一次鑑定所涉及之相同事實進行調查，以更正第一次鑑定結果中或有之不確之處。

第二次鑑定在 510 至 512 條中規範，其具有下列特徵：

在作出第一次鑑定後十天期內聲請或法官於訴訟之任何時刻依職權命令進行（第 510 條第 1 及 2 款）；

第二次鑑定並不使第一次鑑定喪失效力，兩者均由法院自由評價（第 512 條）；

除 511 條各項中的變更外，其他規定與第一次同。

參與第一次鑑定之鑑定人不得參與第二次鑑定；

第二次鑑定一般屬合議方式之鑑定，而鑑定人之數目較第一次鑑定時多兩名，且其中一名須由法官指定。

第四分節

勘驗（prova por inspecção judicial）

54. 勘驗之概念

《民法典》第 384 條規定：“勘驗證據旨在使法院直接了解事實。”

勘驗是指法院對某特定物或人作直接之觀察。

似乎這才是勘驗之最佳概念，而程序方面的規定則載於《民事訴訟法典》第 513 至 516 條。該些規定亦給予法官偕同專門知識之技術人員到場之權能（第 515 條）。

54.1. 名稱（denominação）

勘驗是許多國家立法皆接受之一種證據，雖然制度及用語各有不同。

如此：

——1807 年之《法國《民事訴訟法典》》中之用語（可能不大好）是 “descente sur les lieux” ；

——1865 年之意大利舊《民事訴訟法典》中稱為 “accesso giudiziale” 。在現行法典內稱為 “Ispezione” 。

——1877 年之德國法典內稱為 “Zivilprozessordnung” 及 1895 年之奧地利法典內稱為 “augenschein” ，意謂 “親眼查驗” （exame ocular）。

——1881 年之西班牙《民事訴訟法典》中稱為 “reconocimiento judicial” ；

——瑞士 Vaud 郡之法典稱為爭訟稱的之勘驗（ “inspecção de objecto litigioso” ），據 José Alberto dos Reis 教授所稱，該詞對葡萄牙法典中，即後來澳門特區之法典中所採用者給予啟發。

54.2. 勘驗與其他證據之根本差別

這種證據方法與其他方法之根本分別在於司法勘驗是一種直接證據，在審判者與事實之間無任何中介人，由法官直接搜集證據。

此為完全實行**直接審理原則**之唯一證據方法。由法院搜集證據；在事實與審判者之間不存在任何證據媒體，有別於其他證據方法（間接證據）。

54.3. 勘驗之標的（objecto da inspecção judicial）

第 513 條第 1 款清楚指出勘驗可以不動產或動產為標的，亦可以人為標的。

54.4. 勘驗之目的（finalidades da inspecção）

透過第 513 條第 1 款，我們發現勘驗的目的是澄清對案件之審判屬重要的任何事實。

54.5. 勘驗之手續（formalidades da inspecção judicial）

勘驗證據可以是：

由法官依職權命令進行：如法院認為適宜，得主動或應當事人之聲請，在尊重私人生活之隱私及人之尊嚴下，對物或人進行檢驗，以澄清對案件之審判屬重要之任何事實；為此，得前往涉及有關問題之地方，亦得在認為有需要時，命令重演有關事實（第 513 條第 1 款）。

由當事人申請：如法院認為適宜，得主動或應當事人之聲請，在尊重私人生活之隱私及人之尊嚴下，對物或人進行檢驗，以澄清對案件之審判屬重要之任何事實；為此，得前往涉及有關問題之地方，亦得在認為有需要時，命令重演有關事實（第 513 條第 1 款）。

當事人只可在第 431 條第 1 款所指之期間內聲請，即自通知起計十五天內聲請採取證明措施。

不論所針對的標的為何（動產、不動產或人），只能是為了調查載於調查基礎內容中之事實（第 430 條第 1 款 b 項）。

按第 514 條之規定，必須通知各當事人以便其可參與勘驗有需要將並向法院作出解釋。

第 515 條容許法院在勘驗時有一名技術員（técnico）陪同。此為法官之一各輔助人，目的是在查驗（exame）及理解查證之事實法官加以解釋。

他並非鑑定人（perito）：誰人作出勘驗是法院，而非該技術員，並非該技術員提供證據，是由法官直接觀察。並非由該技術員舉證。

勘驗可由合議庭或獨任庭作出。在後述情況下，需作成筆錄，並由合議庭自由評價。倘由合議庭作出勘驗，則無需作成筆錄，但其結果仍由合議庭自由評價，此為第 558 條第 1 款所賦予之權力但受第 2 款約束。

關於勘驗之證明力，《民法典》第 385 條規定：“勘驗結果由法院自由判斷”。

第五分節 人證 (prova testemunhal)

55. 概念

證人是指：“所有非案當事人，亦非其代理人，但被要求就爭訟中之全部或局部事實說出其所知的一切之人”²⁶。

《民事訴訟法典》第 517 條至第 548 條及《民法典》第 386 條至第 390 條皆述及這種證據。

部分學者指人證乃所有證據之後²⁷。然而，事實上這種證據方法存在許多缺點或不便。有極好之證人，亦有極差之證人；更正確言之，有極好之證言、亦有極差之證言。這正是此方法不好之處。

《民事訴訟法典》先指出無作為證人之能力之情況，之後，詳盡規範關於在法庭之作證之事宜。

另外，《民法典》第 390 條規定：“證人證言之證明力由法院自由判斷”。

55.1. 誰人可訊問證人？

下列者可以訊問證人：

——當事人及

——法庭。

1) 當事人 (as partes)

主當事人 (partes principais)

主當事人自然有權通過法院詢問證人，以調查所陳述之事實之真相。

為此，須提出證人名單 (rol de testemunhas)。而須名單須按第 431 及 432 條規定在十五天期內提出，但當事人最遲可在進行辯論及審判聽證之日期前三十日提供。

第 520 條第 1 款指出：

“證人透過名單指定，而在該名單中須載有證人之姓名、職業及住址，以及其他對認別證人身分屬必需之資料”。

按照第 533 條第 1 款之規定，在通常程序內，對於作為訴之事實依據之證明，不能提出超過二十名之證人；被告人在答辯時亦受相同數目之限制。在反訴之情況下，每方當事人亦可提出二十名證人，以證明有關反訴及作出防禦（第 533 條第 2 款）。

在證人名單內超出數目限制之證人，其姓名視為未經載錄（第 533 條第 3 款）。

然而，對於每個待證之事實，不得詢問超過五個證人（第 534 條）。

²⁶ 見註腳二十七所述之作品，第 102 頁。

²⁷ 最適當之表述方式是 Antunes Varela 所述之：“從各方面言之，法律採納之最重要之最重要之證據為人證”，見註腳四十所述之作品，第 609 頁。

輔助當事人 (partes acessórias)

《民事訴訟法典》第 280 條規定：在人證方面，輔助人只可以利用主當事人有權提出而仍未提出之人證名額。

例如：倘主要當事人提出二十名證人，輔助人則不能提出任何證人；倘前者指出十四個證人，輔助人則有權指出六個證人。

2) 法院

按第 548 條之規定，可由法院主動詢問證人，只要何理由推定某一未被提出作為證人之人知悉對案件之裁判屬重要之事實（該條第 1 款）。

55.2. 誰人可成為證人

第 517 條第一款規定：

“凡未因精神失常而處於禁治產狀況之人，均有成為證人之能力”。

有兩類無資格：

——自然無能力 (incapacidade natural)；

——法定無能力 (incapacidade legal)。

前者屬於概括性：所指之無能力人在任何訴訟內皆不能作證。另一個是特定無能力：只在某些訴訟內被禁止作證。

1) 自然無能力：

按第 517 條之規定，自然無能力無資格作證：

因精神異常之禁治產人，但法官應檢查任何作證言之人的身體及精神之能力。

2) 法定無能力

按第 518 條之規定：“凡在有關案件中能以當事人身分作陳述之人，均不得以證人身分作證言。”

此為理由非常明顯，且是源自羅馬法的規定；同樣地，下列人士得拒絕作證人（第 519 條第 1 款）。

在卑親屬之案件內，尊親屬不能作證，相反亦然。

在女婿或兒媳婦之案件內，岳父、岳母或家翁、家姑不能作證，相反亦然。

在配偶或前夫前妻之案件內，別一方不能作證相反亦然；

與案中當事人以事實婚的方式生活或曾以該方式生活者。

55.3. 向誰人提出人證

指出及識別證人後，通則是證人在辯論及審判聽證中向合議庭作供。但第 522 條亦規定有例外之情況。

不在聽證時作供：

按第 444 條規定須提前被詢問之證人（適用搜證適時原則 (princípio da oportunidade da recolha de provas) 之一種情況）。

用請求書的方式詢問之證人。

按第 525 條之規定，有特權在其住所或工作地點被詢問之證人。

不能到庭之證人（第 528 條所述之情況）。

在 a 項所述之情況下，必須由獨任法官詢問證人；在其他情況下，可以由獨任法官或合議庭詢問證人。

55.4. 作供之地點

關於作供之地點，我們透過第 522 條及第 99 條可間接知道通則是在法院作出。但亦有例外之情況：

在事發地點，只要法院主動認為、或應任一當事人請求認為適宜者（第 523 條）；

因尊重（第 525 條）、或因病而不能到庭（第 528 條），則在某些人之住所進行。

55.5. 作供之手續

應通知證人進行作供。採用**通知**（notificar）這個方法，乃因第 175 條第 2 款之規定（按該條文規定：通知係用於在其他情況下召喚某人到庭或讓其知悉一事實）。

對於當事人應偕同到場之證人，無須作出通知（第 529 條第 2 款）。

55.5.1. 倘證人出席（到庭），應按一定形式進行

警告：第 536 條準用第 484 條：“開始作陳述前，法院須使陳述者知悉其將進行之宣誓在道德上之重要性，以及使其知悉負有據實陳明之義務，並警告陳述者作虛假聲明時將受之處分”。

宣誓：按第 484 條第 2 款之規定，必須宣誓。

初步訊問：第 536 條第 1 款特別提及這一點內容：“須確認證人之身分，並詢問證人與當事人之間是否存有任何血親、姻親、友誼或依賴之關係，或詢問證人就有關訴訟是否具有任何利益”。

同一條文第 2 款補充道：“如法官從該人之答覆中發現依據第 517 條至第 519 條之規定不可作出證言，或發現作證之人非為被提出作為證人之人，則不接納其作證言”。

4) **正式詢問：**對於列入調查基礎內容之（由當事人在訴辯書狀中主張之）事實，詢問由當事人提出之證人（第 539 條第 1 款）。

可以看到，與當事人陳述之步驟一樣。

55.5.2. 誰人進行訊問

須區分下述兩種情況：

向合議庭作證言；

向獨任法官作證言。

倘向合議庭作供，詢問是由提出證人一方之律師進行，反方當事人之律師

可要求作出補充或澄清（第 539 條第 2 款）。合證庭主席及助審法官亦可詢問及要求證人作補充（第 539 條第 3 款）。

倘向獨任庭法官作供，詢問由獨任法官作出，當事人之律師可要求補充或澄清有關答案。

55.6. 關於供詞可出現之附隨事項

關於證人之供詞，可出現《民事訴訟法典》第 537、538、543 至第 546 條以及第 640 至 643 條所規範之附隨事項。

其中有：

爭執（impugnação）；

反駁（contradita）；

對質（acareação）。

55.6.1. 爭執（impugnação）：

倘證人無能力或無資格作供，證言所針對之當事人可就接納有關人證一事提出爭執，基於相同之依據法官應拒絕其作證言（第 537 條）。

爭執須於初步訊問後提出；如所提出之爭執獲接納，須就有關事實事宜向證人發問；如證人不承認該事實事宜，則提出爭執之人得以文件或透過其偕同參與爭執之證人，證實該事實事宜，但就每一事實不得提出多於三名證人。法院須立即裁定證人應否作證言（第 538 條第 1 及第 2 款）。

55.6.2. 反駁（contradita）

藉此附隨事項嘗試削弱證人所作供詞之證明力。第 543 條容許這點：“提出之證人所針對之當事人得反駁該證人，陳述任何可質疑有關證言之可信性之情況，不論係透過針對證人所援引之科學理由之方法或透過使人對證人之信任程度降低之方法為之”。

因此容許通過所作之供詞攻擊：

由證人所提出之科學理由；或

或其可信性。

例如：“證人所述之科學理由為其目睹有關事實或事實發生時他在現場。在此情況下，他方當事人可反駁，主張證人不能目睹因為他是失明者，或在事發時，他身處另一個地方，不可能在現場”²⁸。

必須在作供完畢後提出反駁（第 544 條第 1 款）。須指出作為反駁所依據之事實；倘反駁被接納，則聽取講述有關事宜之證人之解釋。

在爭執（impugnação）時，須立即提出所有證據；在反駁（contradita）時，應立即提出證人；但文件最遲可於對事實作出決定之前提出（第 544 條第 2 及 3 款）。

²⁸ 見由 José Alberto dos Reis 著之《民事訴訟法典評釋》，第四卷，第 437/438 頁。

55.6.3. 對質 (acareação)

對質是最後一個要考慮，同證人證供有關之附隨事項。

目的是解決各證人證供所述事實間、或證人與當事人所述之事實間之矛盾。

第 545 條規定：“對於某一事實，如各證人之證言間或證人之證言與當事人之陳述間有直接矛盾者，得依職權或應任一當事人聲請，該出現矛盾之人對質”。

對質可由當事人聲請或由法官依職權權而作出。

如有關之人均在場，則立即進行對質；如不在場，則指定日期進行該措施（第 546 條第 1 款）。

55.7. 證人缺席

假設證人名單中之其中一名證人、在詢問所定之期日及地點缺席，法律上如何解決之？

須考慮兩種情況：屬當事人承諾偕同到場之證人，或法院通知到場之證人（testemunha notificada）。

55.7.1. 當事人承諾偕同到場之證人

倘缺席，如他方當事人同意，可以押後詢問，一如《民事訴訟法典》第 530 條第一款 b 項所規定般：“如不能作證言之情況屬確定性，當事人得更換證人（第 530 條第 1 款 a 項）”。

55.7.2. 由法院通知、但缺席之證人

這種缺席可以引致：

押後詢問 (adiamento da inquirição)：此為第 530 條第 2 款 a 項所規定，詢問時證人缺席者，須遵守下列規定：“如應對該證人作出通知，但未有作出，又或該證人因其他正當障礙而不能到場者，則押後詢問；但不能於三十日內對其進行詢問者，當事人得更換該證人”。

更換證人

提出證人後、證人之遷往澳門以外地方居住

第 530 條第 1 款 c 項容許以此為依據而更換證人：“如證人已遷往澳門以外地方居住，則當事人得更換證人、承諾於重新指定之日期偕同證人到場，或向法院聲請依據第 524 條第 3 款之規定命令該證人到場”。

無作出屬於強制性之通知

同條第 2 款 a 項規定：“如應對該證人作出通知，但未有作出，又或該證人因其他正當障礙而不能到場者，則押後詢問；但不能於三十日內對其進行詢問者，當事人得更換該證人”。

證人無合理理由而缺席，且無法將其尋獲

第 530 條第 2 款 b 項規定：“如屬無合理解釋而缺席，且無法尋獲該證人，以致未能依據第四款之規定使其作證言者，得更換該證人”。

缺席可引致的其他後果：

承諾於重新指定之日期偕同證人到場見第 530 條第 1 款 c 項。

55.8. 對證人開支的補助及損害賠償

第 547 條規：“曾被通知到場之證人，不論其是否居於澳門及有否作證言，均有權收取往來之開支及就其到場之每一日收取法官所定之損害賠償，只要證人於作證言時，或於獲告知無須接受詢問時提出該請求，又或無該告知時，於送交卷宗以作判決前提出該請求”。

後上條得知證人可以收取：

——交通費；及

——損害賠償。

兩者均須由法官訂定。

第五節

辯論階段（fase de discussão）

56. 辯論之概念

辯論階段是當事人對證據作出批評性分析，展示及解釋適用於既證事實之法律，同時指出因適用該法而產生之法律後果的階段。

辯論階段始於辯論及審判聽證（是指法院對事實進行調查、辯論及審判，按 549 條及隨後數條連續及集中地進行工作的階段，Paulo Cunha 教授稱此為總體聽證）。

在現實裏（雖然有一定之重覆性，因為總體聽證地包括調查活動），現在我們要學習的是整個辯論及審判聽證，而非構成該聽證其中一部份之辯論階段。

在聽證時，開展下述活動：

大部分調查活動（第 555 條第 3 款 b、d 及 e 項）；

部分辯論活動；

進行事實審判。

聽證以公開、莊嚴及口頭形式進行。

特別是後者，代表**口頭原則**之應用，現在我們作深入之分析。

57. 口頭方式。其批評性評論

57.1. 定義

上文已指出，**口頭原則**乃大部分訴訟活動所採用之原則，尤其是調查及辯論，皆以口頭方式進行，目的是透過生動之報告及描述，而非沉重而死版之卷宗，使法官直接接觸問題。

口頭方式是純羅馬之訴訟法原則。“只可相信證人，而非證言……，一方面是對在場證人之信任問題，另一方面是習慣性地宣稱之證言”，此為羅馬法典（Digesto）²⁹之言論。

口頭制度已被廣泛討論，有人讚成、亦有人反對，有其優點及缺點，但並無決定性續論。

支持口頭原則的如 Chiovenda，而此原則基本上載於所有之現代訴訟法典中，包括葡萄牙及澳門特區之法典。

57.2. 現在我們重點分析辯論（discussão）

一如在葡萄牙《民事訴訟法典》法淵源一章內所述般，至 1926 年實行訴訟法律改革之前，以往民事案之辯論皆以書面形式進行。除了各種不便外，主要之缺點是將辯論作成書面，變得乏味及表達性不足。

事實上，**口頭原則**會以更生動、更感性方式對待問題，會使爭訟之問題更具人性之體現。

²⁹ 見 D.22.5.3.3.

自 1926 年之法律至今，趨勢是採用**口頭原則**，並同時採用**集中審理原則**，使辯論及與證據之訴訟活動（盡可能）集中在一個聽證或在短期內連續進行之幾個聽證內。

口頭制度採自歐洲各國的法律，其中計有英國、法國、德國、奧地利及匈牙利。

而作為**口頭原則**之必然補充內容，有其他原則：

集中審理原則

法官完全參與原則——載於第 557 條

第 557 條規定：“曾參與在辯論及審判聽證中作出之所有調查及辯論行為之法官，方得參與對事實事宜之裁判”。

目的是使參與審判及作出事實審由同一組法官負責。為確保這一點，規範是：如任何法官於辯論及審判期間死亡或長期不能參與，則先前所作之行為須重新作出；如屬暫時不能參與，則中斷聽證一段必要期間，但有關情況顯示重新作出先前所作為屬較適宜者除外；對決定中斷聽證或重新作出行為之裁判不得提起上訴，但該裁判由應主持繼續進行之聽證或主持新聽證之法官以附有理由說明之批示作出。

被調任、任用於更高職級或退休之法官，應先完成有關審判；但屬強迫退休或因無能力擔任有關職務而須退休者，或在上述任一情況下，依據上款規定重新作出先前所作行為屬較適宜者，均不在此限。

連續原則（princípio da continuidade）

第 559 條第 2 款規定：“聽證係連續進行，僅因不可抗力、有絕對需要，或在第 553 條第 4 款、第 554 條第 4 款、第 555 條第 6 款及第 557 條第二款所指之情況下，方得中斷”。

為了使聽證之各個階段之間不會有太長之空檔時間，亦為了避免中斷，在假期期間法庭仍可運作，為此第 559 條第 1、2 及第 3 款規定了各種措施。

公開原則（princípio da publicidade）

以澳門特別行政區司法組織綱要法（十二月二十日之第 9/99 號法律第 9 條之）規定為基礎，這個原則並且明示地載於《民事訴訟法典》第 559 條第 1 款中。

按一般規定聽證是以公開形式進行，但第 118 條第 2 款 a 項所述之情況則除外：撤銷婚姻之訴、離婚、及與親子關係的建立或爭執有關的訴訟，以及法院認為須保密者。

口頭制度（sistema da oralidade）是以上述各原則為基礎。

這個制度是否行之有效？

在創立後不久，有不少反對之聲音，但毫無疑問地，支持之意見仍佔大多數，實踐指明了口頭原則並非經常發揮如期之效果。

58. 辯論及審判聽證前之預備（preliminares da audiência de discussão e julgamento）

我們先看看**辯論及審判聽證**之預備手續，其中分成下列步驟：

按第 431 條第 1 款的規定通知各方當事人，以便其除作出其他的聲請外，亦可在十五天內聲請將辯論及審判聽證錄前成視聽資料；

指定進行辯論及審判聽證的日期(第 431 條第 3 款)；而對於損害賠償訴訟，按 550 條的規定在指定日期方面有其特殊性；

送交合議庭助審法官檢閱(第 551 條)；繳付審判之預付金。

59. 在誰人面前進行辯論

根據 549 條第 1 款的規定，**辯論及審判**在合議庭之情況下進行。

在**通常訴訟程序**內，僅**事實審判**由合議庭審理；**法律審**在判決書內由合議庭主席作出。然而，該條第 2 款規定了一些例外的情況，在該等例外的情況下，僅當事人獲通知後(第 431 條)十五天內提出聲請時，合議庭方參與審判。

60. 聽證之手續 (formalidades da audiência)

聽證按下述方式進行：

合議庭之組成

如不能組成合議庭，將押後聽證。

然而，組成合議庭後，亦可以有引致押後之其他理由，為此，接著需要：

審查有否押後之理由

第 554 條第 1 及 2 款規定：

一經召喚已被傳召之人，聽證立即展開；

然而，遇有下列情況，聽證須予押後：

須由合議庭參與聽證，而不可能組成合議庭；

某一已被傳召之人缺席，而其未被免除到場，或對於一份已提交之文件，即使中止聽證工作一段時間，他方當事人仍不能在聽證中查閱該文件，且法院認為在該缺席之人不在場或就該文件未作答覆之情況下進行聽證有嚴重不便者；

其中一名律師缺席，而其缺席一事須告知委任人；在此情況下，須立即指定聽證日期，但對缺席之律師，無須遵守第 105 條第 1 款之規定。

注意：法律禁止藉當事人之協定而押後聽證(《民事訴訟法典》第 554 條第 3 款)。

倘聽證繼續進行，則開始另一個步驟(階段)：試行調解(第 555 條第 2 款)。
舉證(提出證據)(produção de prova)

第 555 條第 3 款 a、b、c 及 d 項規定：

——當事人作陳述；

——展示機械複製品；

——倘之前曾進行鑑定，鑑定人需按要求作出解釋；

——訊問證人。

接著進入另一個階段：

就事實事宜進行辯論

辯論要遵守第 555 條第 3 款 e 項之規定，每個律師可以反駁一次。

亦須遵守同一條文第 7 款之規定：“……律師應儘可能確定應視為獲證實獲之事實及未證實之事實……”。

61. 事實審 (julgamento de facto)

61.1. 辯論結束

辯論結束後，合議庭退回會議室進行事實審。如前所述，合議庭只以自由心證方式審理**事實事宜**（第 556 條第 1 款及第 558 條）。

事實事宜是通過**會議庭裁判** (acórdão) 裁定之（第 556 條第 2 款）。

在調查基礎內容中，合議庭裁判中要指出那些事實合議庭認為已獲證實而那些會議庭認為未獲證實（第 556 條第 2 款）。

對於視為已證之事實，合議庭須對其答案作出**理由說明**，並詳細說明構成審判者心證之決定性依據 (fundamentos decisivos)（第 556 條第 2 款最後之部分）。

合議庭之裁判按大多數票決定，而合議庭裁判書，由會議庭主席製作，主席及其他助審法官可在簽署時指出對於裁制某些內容投票落敗，亦得就理由說明部分作出不同立場之聲明（第 556 條第 3 款）。

作成合議庭裁判後，由會議庭主席宣讀，接著讓當事人律師查閱裁判的內容（第 556 條第 4 款）。

61.2. 對合議庭裁判提出異議

查閱後，律師可對內容之缺漏、含糊不清或前後矛盾、或欠缺理由說明為依據而提出**異議** (reclamação)。

異議應立即提出，法院從新開會，以便對異議作出裁判。不得對關於異議之裁判另行提出另一次異議（第 556 條第 5 款）；然而，倘對最後判決提出上訴³⁰，中級法院可以、甚至是依職權，更改事實事宜之裁判，只要出現第 629 條第 1 款 a、b 及 c 項的情況，甚至在認為內容有缺漏、含糊或矛盾時，將裁判撤銷。此外，應利害關係人之聲請，中級法院可以命令初級法院就對案件的裁判屬必的事實說明裁判的理由（第 629 條第 5 款）。

對合議庭裁判之異議必須立即提出之規定，似乎可受到批評。

但事實上，調查基礎內容的範圍往往使律師不能注意到某些內容之缺漏，未能即時提出異議。

62. 對案件法律事宜之辯論

對合議庭裁判所提出之異議作出裁判後，或並無人提出異議，則開始對案件之法律事宜之進行辯論（第 556 條第 6 款）。

該辯論可用**書面**或**口頭**方式進行。

³⁰ 針對合議庭所作出的事實事宜的判決是不能上訴的，因為它只是一個單純預備判決行為。

欲使用口頭方式進行，當事人間必須達成協議（第 556 條第 6 款）。

倘當事人並無協議以口頭方式進行，則用書面陳述方式進行（第 560 條）。

口頭辯論立即進行，並非在合議庭面前進行，而是在制作告終局判決之法官面前作出。

此為第 556 條第 6 款之規定，且補充道：關於對法律事宜辯論之形式，按第 555 條第 3 款 e 項關於對事實之辯論所作之規定，律師嘗試解釋法律及將其適用於視為既證之事實。

倘當事人並無協議用口頭辯論，事實審完成後，辦事處先將卷宗供原告人之律師檢閱，之後是被告人之律師，各有十天期間，目的是作出書面陳述，解釋法律及將其適用於視為**既證之事實**。

而按第 560 條之規定，辯論則以**書面**形式進行。

第四節

判決階段（fase da sentença）

63. 判決之概念

在判決階段，對案件作出裁判。

判決乃法官對主訴訟或任何具有訴訟結構之**附隨事項**作出裁判之行為。

此為第 106 條第 2 款所給之概念。

63.1. 如何開始判決階段

如何開始判決階段？

第 561 條規定如下：“案件在法律方面之辯論終結後，須將卷宗送交法官，以便其在二十日內作出判決”。

我們在上文已知道由那一位法官制作判決書。

在此階段，我們應考慮兩個行為：

將卷宗送交法官；

作出判決——應在二十天期內作出。

63.2. 判決之內容及其形式

在判決書內須區分：

基本元素；

次要之元素或偶然之元素。

前者為判決之基礎部份，欠缺該部分則判決視為不存在（inexistentes）或無效。

後者屬必須之部分，但已顯現在訴訟法律關係內。例如：判交付訴訟費用，或對惡意訴訟（litigância da má fé）判處罰款，作出通知之命令。

63.2.1. 基本元素（第 562 條）

基本元素包括：

敘述部分（relatório）

指出案之主體及客體要素。

審查程序是否符合規定

作成**敘述部分**後，法官須審定在清理批示內審理，且按第 429 條第 3 款之規定須留待判決時解決之訴訟前提。此為第 562 條第 1 款之規定。

說明理由（fundamentação）（第 562 條第 3 款）

依據（fundamentos）乃裁判之理由，包括兩部分：

（1）——事實部分；

（2）——法律部分。

事實依據（根據）乃限制法律規則適用之事實（分條縷述之事實，明顯之事

實，依職權視為既證之事實，推定的事實及會議庭證實之事實）。法官須指出引致法律規範適用之既證事實。

法律依據（fundamentos de direito）乃指適用於事實，決定所採用之解決方法之法律規定。

判決之結論部分（conclusão da sentença）

接著是結論，只不過是法院之裁判，即對訴之理由成立或不成而作出審判。訴之理由可為全部或局部成立。法官可裁定訴訟只是部分理由成立。

日期及法官之簽名（第 107 條第 1 款）

然而，除了這些（基本）元素外，判決還應包括某些特定次要元素。

63.2.2. 偶然元素（elementos acidentais）

判決支付訴訟費，第 376 條第 1 及 2 款述及此點：

“1. 審理訴訟或其任何附隨事項或上訴之裁判須判處引致訴訟費用之當事人負擔該費用，或無人勝訴時，判處從訴訟中取得益處之人負擔該費用”。

敗訴之一方當事人視為引致訴訟費用之人，而該費用按其敗訴之比例計算。”

對可能發現之惡意訴訟作出裁判（第 385 條第 1 款）

“而同條的第 2 款則對惡意訴訟下了定義”。

判處支付代理費用：

十月廿五日第 63/99/M 號法令通過之司法費用制度第 26 條第 1 款…

“勝訴當事人有權就每一審級，按獲勝訴之比例，向敗訴當事人、撤回訴訟之人及捨棄請求之人或作認諾之人，以算入訴訟費用之職業代理費名義收取一筆款項，但屬附隨事項者除外；上述規定不影響關於司法援助之規定之適用。”

63.2.3. 判決之形式

按第 107 條之規定：司法裁判書須經法官或裁判書製作人註明日期及簽名，而其應在非以手寫之各頁上簡簽及作出必需之更改聲明；如屬合議庭裁判書，尚須由參與作出裁判之其他法官簽名，但該等法官不在場者除外；在此情況下，須予以載明。

64. 不正當利用訴訟

第 568 條規定：“如當事人之行為或案件之任何情節，使人確信原告及被告利用訴訟，以作出虛偽行為或達致法律禁止之目的，則有關裁判應防止當事人欲達致之不正當目的實現。”

這條規範複述 1939 年葡萄牙事訴訟法典之相同規定，是阻止或打擊訴訟上之虛偽行為之其中一個手段。

另一個是**第三人反對之非常上訴**（recurso extraordinário de oposição de terceiro）第 664 條至 669 條之規定。

很多時，在某些訴訟內往往發現當事人雙方隱藏了一目的對方，希望實現一個違反法律之目的。這種當事人隱藏之目的，有別於該當事人雙方在訴訟裏所外顯之對抗態度，此構成訴訟上虛偽行為的特徵。

相對來說這些行為出現之情況也十分常見。

例如：在調查父親身分之訴裏，為了使判決不就其應確立之實況雙方而作出，當事人促使訴訟向權利不如實際應界定的方向。

更具體的如提起一宗調父親身分之訴，為了使訴訟不會被裁定理由成立及宣告親子的關係，原告透過收取某特定金額，不提出適當證據而使自己敗訴。

後前，按照當時生效之法律，提起訴訟以達致違法目的，例如：目的是變更婚姻之財產制度。配偶約定離婚，離婚後重新結婚，訂立一個不同之財產制度。此為欺詐訴訟（processo fraudulento）之一種典型情況³¹。

有人指出：制訂法律後，亦產生不好的東西。產生了不好的東西後，則需要有對付該等不好東西的手段。

很久以前就嘗試打擊（表面為合法的，但實際上是為當事人間）之利益而作出之不合法行為。

在 1876 年之葡萄牙《民事訴訟法典》生效時，這個問題更為嚴重。其中在該法典第 148 條規定：對已確定之判決只可以透過撤銷既判案之訴而撤銷，同時必須以該條文明示所述之依據為基礎。

在這些依據中，並不包括訴訟上的虛偽行為；在透過虛偽行為而獲得判決之情況下，並無針對該判決作出防禦方法。

當時各學者在雜誌上發表意見甚至法院亦作出裁判，認為事實上，在法律方面無對抗訴訟上之虛偽行為之方法。

撤銷判決之訴乃撤銷確定判決之特有方法，由於只有在有第 148 條所指之依據之情況下，方才可提起訴訟，而訴訟上之虛偽行為並非這些依據之組成部份，因此，以當事人之虛偽行為而作出之判決是可質疑的。

很明顯這種趨勢產生許多不便，學理開始找尋各種解決方案，目的旨在避免在額訴訟上之虛偽行為之情況下作出之判決。

由於有這個需要，在草擬 1939 年葡萄牙《民事訴訟法典》時，這個問題再次被受評擊：故在法典內加入了上述兩個解救方法——仍一直保留至現行之葡萄牙法典及澳門特區之法典內：

如法官確信雙方當事人利用訴訟以達致虛偽行為或違法之目的，則應防止他們之不正當目的實現（第 568 條）。

倘法官沒有使用第 568 條賦予之權能，則受損害之第三人、可透過“第三人反對而提起非常上訴”（第 664 條至第 669 條）。

在這裏我們只提及上述兩個解決方法中之第一個。

試分析第 568 條，其似乎是指作出一個形式上之裁判。

³¹關於欺詐訴訟（processo fraudulento）與虛偽訴訟（processo simulado）的區分，請參看 Alberto dos Reis 教授的《民事訴訟程序註釋（Código de Processo Civil Anotado）》，第 5 卷，第 101 頁。

該條文指出：如當事人之行為或案件之任何情節，使人確信原告及被告利用訴訟，以作出虛偽行為或達致法律禁止之目的，則有關裁判應防止當事人欲達致之不正當目的實現。

很明顯，法官必須在訴訟內明示地指出這種心證的依據，尤其是第 568 條所述之裁判部份，因在上訴時將受上級法院之審查。

這種心證須源自經法官查明的，且不論當事人有否主張均不採用的事實，一如第 567 條所規定般，但必須清楚指出這些事實。

在此較易明白到：不適用當事人在訴辯書狀中主張之事實之限制，因為當事人絕不會在訴辯書狀中主張可證明他們法律欺詐（defraudar a lei）之事實。

倘知悉有詐欺之情況，法官如何能作出阻止？

法官只可防止當事人欲達致之不正當目的的實現，因而不審理實體問題。因此，訴訟欺詐乃阻止法院審理實體問題之情況。

按照第 412 條第 2 款之規定；妨礙法院審理案件實體問題之事實構成延訴抗辯之特徵。

雙方訴訟欺詐是另一個延訴抗辯之理由，第 413 條所列僅具者之另一情況。

倘適用第 568 條，法官應該及可以作出之行為是不審理實體問題，同時駁回對被告人之起訴，依據是被告原告開展訴訟欺詐活動。

65. 判決內容之限制（limites da condenação）

判決有如下限制：

關於標的；

關於人；

關於依據；

a) 關於標的（quanto ao objecto）：

第 564 條第 1 款規定：第五百六十四條判處範圍，一、判決時所作之判處不得高於所請求之數額或有別於所請求之事項。

第 571 條第 1 款 e 項規定：第五百七十一條判決無效之原因，一、遇有下列情況，判決為無效：e) 所作之判處高於所請求之數額或有別於所請求之事項。

b) 關於人（quanto às pessoas）

不得對無參與訴訟之其他人作出判決或駁回。

倘對第三人作出判處，該人可以對判決提出上訴（第 585 條第 2 款）。

c) 關於依據（quanto aos fundamentos）

第 567 條第 2 部分之規定：法官僅得採用當事人分條縷述之事實，但第 5 條及第 434 條所述之情況則除外。

66. 判決之效果（efeitos da sentença）

判決產生下述效果：

對案件作出裁判及消滅訴訟法律關係（第 106 條第 2 款及第 229 條 a 項）。

事實上，是透過判決而實行審判，亦為消滅訴訟關係之形式

形成**既判案**（caso julgado）——可以是**實質既判案**或**形式既判案**，因應是否對爭議之實體問題作出裁判而定（第 575 條至第 577 條）。

倘為給付判決（sentença condenatória），則屬於執行名義（título executivo）（第 677 條 a 項）。

關於上述之第一種效果——消滅訴訟法律關係，需注意：對於部分學者來說，如 Chiovenda，上訴階段並非新訴訟法律關係之開始。因此，判決並無消滅訴訟法律關係，倘進入上訴階段，則該關係仍繼續。

然而，大部分訴訟法學家皆認為提起上訴產生一種新之訴訟關係：上訴關係（instância de recurso）。

似乎按照現行法律，這點較為正確。

67. 判決之公開性

有兩種形式：

判決之通知——按第 200 條第 1 款之規定，應將判決通知訴訟代理人；

判決之登錄——在法院辯事處之專門簿冊內登錄判決（第 107 條第 3 款）。

68. 判決之瑕疵與補救

68.1. 判決之瑕疵

判決，作為人類活動之成果，可以有不完美之處及帶有瑕疵。

可有兩方面之瑕疵：

實體或內容瑕疵（vícios substanciais ou de conteúdo）：

跟裁判之實體問題有關；跟錯誤認定事實及法律規範有關；與裁判之不公正有關；亦與法律秩序不符有關。

形式瑕疵或活動之瑕疵（vícios formais ou de actividade）

跟在實體問題上之司法裁判之不完美有關；

就實體或內容瑕疵（錯誤裁判、將法律錯誤地適用於事實）之補救方法是上訴。

關於形式或活動瑕疵，法律規定了特別之補救方法——載於《民事訴訟法典》第 569 條及第 570 條。

形式或活動瑕疵有四種：

實體上之遺漏、誤寫或不正確（第 570 條）；

判決之無效：第 571 條述及此點。

然而，不應將**判決之無效**與**程序無效**相混淆：程序無效同訴訟行為是否合規則有關，而**判決之無效**只是關於所作出之裁判之瑕疵。

判決含糊或出現一詞多義的情況。倘判決在其文本上欠缺清晰，則判決為含糊。倘其意思可產生各種不同之解釋，即產生不同之意思，此為多義（第 572 條 a 項）。

就訴訟費及罰款作出錯誤判處（第 572 條 b 項）。

68.2. 瑕疵之補正

現在我們看看法律為每一種形式或活動瑕疵所定之補救方法。

對於實體上之遺漏、誤寫或不正確之情況，補救方法是作出更正——按照第 570 條之規定，可以是應當事人之聲請、或依職權作出；倘無上訴，可於任何時候作出，或直至上訴上呈時作出。

關於**判決之無效**，補救方法是補正無效之情況（第 573 條）。

關於判決之含糊或一詞多義的情況，當事人只可以聲請法官澄清其裁判決定（補救方法是作出解釋，一如第 572 條 a 項所述般）。

就訴訟費用或罰款作出錯誤的裁判的情況，補救方法是聲請作出糾正判決（第 572 條 b 項）。

這些補救方法所遵從之形式列於第 573 條：聲請期限為十天（第 103 條），通知另一方當事人在相同期間內作出答覆；之後作出新裁判。

倘任一造當事人申請更正、澄清或糾正判決，上訴期間³²僅自通知對聲請作出之決定後開始計算（第 573 條第 3 款）。

然而，上述通則有一個極重要之例外之情況（第 571 條）。

倘欠缺法官之簽名，可依職權或應任一當事人之聲請而補正，只要補簽屬可能者則可（第 571 條第 1 款 a 項及第 2 款）。

倘無詳細指明作為裁判理由之**事實及法律依據**；或倘依據與裁判之間有矛盾；或有遺漏判處或判處超出了範圍，或判處之數額高於請求、或有別於請求之標的（第 571 條 b 至 e 項之情況），則：

倘可對判決提起**平常上訴**，則只可在上訴裏主張判決無效；或

倘判決不容許上訴，則向作出判決之法院提出補正請求。

此為第 571 條第 3 款之規定。

在通常訴訟程序中，如對判決可提起上訴者，則只可在上訴中提出判決無效。

倘當事人放棄上訴，一如第 586 條第 1 款所規定般，則可向一審法院提出異議。

應注意：除了第 571 條所定之無效外，還有另外兩種無效情況可見於上級法院之合議庭裁判內：未經必須之表決，以及內容違反表決中勝出之立場之會議庭裁判書（第 633 條第 1 款）。

何謂內容違反表決中勝出之立場，見於第 634 條的規定。

69. 簡易訴訟程序

69.1. （訴辯書狀）階段

簡易訴訟程序見規範在第 670 條及續後數條中，作為補充規定，先適用法典內之一般及共同規定，之後是規範**通常訴訟程序**之規定（第 372 條第 1 款）。

³² 十日，見《民事訴訟法典》第 591 條。

規範簡易訴訟程序之法律，係通常訴訟程序之基本形式之一種偏離，我們是後此角度進行學習，指出這個制度之特別之處。

在訴辯書狀階段內，我們發現簡易訴訟程序及通常訴訟程序有重要分別之處，例如，有簡化的起訴狀：

- 無須陳述法律理由（第 670 條第 1 款 b 項）；
- 無須分條縷述；
- 立即提供證據。

另一不同之處是期間較短：答辯期間及對答辯作出答覆之期間均為十五天。沒有被告之再答辯。

因此，在簡易訴訟程序中通常只有兩個訴辯書狀：

起訴狀；

答辯狀。

但從第 672 條中得知，例外地可出現第三個訴辯書狀——對答辯的答覆。

在此行為中僅可就抗辯或反訴的事宜進行辯論，就其他的事實事宜則不可，在簡易訴訟程序中，該訴辯書狀的作用與通常訴訟程序中之原告之反駁不同。

另一個特別重要的不同之處是在第 671 條第 1 款規定“須傳喚被告以便其於十五日期間內答辯。”及在答辯時需遵守第 672 條第 1 款規定“如被告提出反訴或有關訴訟為消極確認之訴，原告得於接獲依據第四百一十一條之規定命令作出之通知後十五日內，就答辯作出答覆。”

69.2. 不利之後果

正如第 673 條第 2 款第 1 部份之規定，在簡易訴訟程序中規範的不利後果與在通常訴訟程序中規範者相同。

但需注意：在下述情況下不產生不利之後果（第 673 條第 2 款準用之第 405 條第 1 款及第 406 條的規定）：

倘被告為無行為能力人；

倘為共同訴訟的情況，其中一名被告提出答辯；

倘屬不可處分之權利；

倘屬必須通過書證方可證明之事實。

倘被告有多名且非上述 a 項及 b 項之情況時，不作答辯者馬上會被判處，而續後之訴訟階段只是針對曾答辯之人，因而出現一個訴訟關係之主體變更之情況。

在其後之階段中亦可看到程序的簡化及快捷的特點：

——訴辯書狀階段結束後，法官可立即審理延訴抗辯及須依職權審理之無效的情況（第 673 條第 1 款）；

——如訴訟繼續進行，須立即指定進行聽證的日期，且必須於三十日內進行（第 673 條第 4 款）。

這與通常訴訟程序中的規定明顯不同（第 431 條第 3 款）。

其他不同之處在於證人的數目較少（第 674 條第 1 款），以及鑑定人的數目亦較少（第 675 條）。

至於辯論及審判聽證方面，僅在延遲的情況有所不同（第 676 條第 1 款）以及進行的程述較簡化（676 條之其餘各款）。

在判決的結構方面，法律要求有關之依據必須扼要（第 676 條第 6 款），且須以上述方式作成後載於筆錄中，但法官鑑於案件的複雜性，“認為應以書面作出判決者除外”（第 676 條第 7 款）。